

——李某盗窃案	160
39. 侦查机关以其他事由通知到案行为的定性	164
——许某某掩饰、隐瞒犯罪所得案	
40. 形迹可疑型自首的把握认定	168
——阮某抢劫案	
41. 重大立功情节中如何认定提供线索对侦破案件或抓捕犯罪嫌疑人具有“实际作用”	171
——柳某受贿案	
42. 主动到案之初拒不供述犯罪事实的不构成自首	175
——林某等诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得，偷越国(边)境案	
43. 行为人自动投案前，司法机关已掌握行为人主要犯罪事实的“如实供述”时间界限认定	178
——巫某销售假冒注册商标的商品案	
44. 认定自首时对行为性质的辩解与翻供的区分	182
——黄某甲放火案	
45. 单位负责人检举的与单位生产经营无关联性的他人犯罪，不能认定为单位立功	186
——张某等假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案	
(三) 数罪并罚	
46. 漏罪发现的时间可以客观证据存在时间为标准	192
——张某贩卖毒品案	

6 中国法院2025年度案例·刑事案例一

47. 前罪因客观原因未处理，后罪刑罚执行完毕后又犯与前罪同种
罪名之新罪，未处理前罪与所犯新罪应作一罪处理 196
——徐某某诈骗案

48. 在被假释以前发现漏罪，但在假释考验期限内被采取刑事强制
措施的，仍应当撤销假释 199
——侍某某诈骗案

（四）缓刑

49. 撤销缓刑案件的审查标准 203
——苏某某诈骗案

50. 直系亲属主动上缴爆炸物应作为对被告人量刑和适用缓刑的酌
定从轻情节 207
——肖某某非法储存爆炸物案

51. 社区矫正机构对被告人作出调查评估否定性意见情况下慎用缓
刑 210
——余某某危险驾驶案

52. 跨越缓刑考验期的连续犯罪应整体认定 214
——何某虚开增值税专用发票案

53. 行为人“拒不认罪”的情况下，能否适用缓刑 217
——和某某虚开发票案

三、刑事证据

54. 被告人零口供、被害人前后陈述矛盾、证据单一，如何根据现
有证据认定构罪 222
——蒋某强奸案

55. 强制猥亵案被告人翻供的审查认定	226
——林某强制猥亵案	

四、程 序

56. 重疾罪犯收监执行审查应建立专家会商机制	230
——林某帮助信息网络犯罪活动案	

一、犯 罪

(一) 犯罪和刑事责任

1

行为人暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，
虽未构成轻微伤，其行为也应以袭警罪定罪处罚

—— 梁某1、梁某2袭警案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区百色市中级人民法院(2023)桂10刑终207号刑事裁定书

2. 案由：袭警罪

【基本案情】

2022年10月31日13时许，黄某驾驶桂L1×x××蓝色货车运送砂石行驶至某村，与被告人梁某1驾驶的桂L8×x××红色货车相遇，双方互不避让，后群众报警。接警后的民警罗某某、辅警黄某某来到现场，劝导梁某1将车辆驶离，否则将车辆拖走以确保道路畅通。梁某1非但不听反而让路过现场的被告人梁某2(梁某1父亲)回家拿来汽油、镰刀，扬言将车辆烧毁，两被告人在与民

警对峙过程中造成民警罗某某受伤。经法医鉴定，罗某某的损伤程度未达轻微伤。

另查明，2022年10月31日，公安局民警在某村抓获被告人梁某1、梁某2，并依法扣押作案工具铁质镰刀二把。

【案件焦点】

民警罗某某的损伤程度未达轻微伤，二被告人能否以袭警罪定罪处罚。

【法院裁判要旨】^①

广西壮族自治区田东县人民法院经审理认为：被告人梁某1、梁某2暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第五款之规定，构成袭警罪。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。在共同犯罪中，被告人梁某1、梁某2均积极实施犯罪行为，没有明显主次之分，不宜区分主从犯，应按二人所参与的全部犯罪处罚。被告人梁某2到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并且当庭认罪，依法可以从轻处罚。

对于被告人梁某1提出，民警罗某某、黄某某并没有对其进行劝导，其没有与民警对峙，是民警对其进行殴打，其拿起警棍只是正当防卫，罗某某的伤是他与另一个民警在按压其父亲的过程中受伤的辩解意见。法院认为，人民警察在接警后着警服并佩戴警用装备到现场处置报案人请求事项，符合法律规定，具有合法性、正当性，是依法执行公务的行为。民警到达现场后多次劝解梁某1将堵路的货车驶离，要通过合法途径解决其诉求，不能阻碍道路通行，并告知其阻碍行为的违法性，但是梁某1拒不配合并且在听到民警要将其货车拖走后让梁某2将汽油及镰刀带到现场，民警多次警告无果后遂对二被告人采取控制措施并无不当。同时，四位证人的证言、被告人梁某2的供述以及执法记录仪视频均能相互印证梁某1、梁某2在民警执行公务过程中不服从现场执勤民

^①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

警的指挥，反而使用暴力袭击正在依法执行公务的民警，二被告人的行为已构成袭警罪，事实清楚，证据确实、充分，不予认定正当防卫。故，该辩解意见本院不予采纳。

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定：“……违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”本案中，随案移送暂扣于公安局的作案工具铁质镰刀二把，依法予以没收，上缴国库。

现根据被告人梁某1、梁某2的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第五款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

- 一、被告人梁某1犯袭警罪，判处有期徒刑一年六个月；
 - 二、被告人梁某2犯袭警罪，判处有期徒刑一年；
 - 三、暂扣于公安局的作案工具铁质镰刀二把，予以没收，上缴国库。
- 一审宣判后，梁某1提出上诉。

广西壮族自治区百色市中级人民法院经审理认为：上诉人梁某1、原审被告入梁某2暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成袭警罪，应予惩处。在共同犯罪中，梁某1、梁某2所起的作用相当，均为主犯，应按二人所参与的全部犯罪处罚。梁某2到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并且当庭认罪，依法可以从轻处罚。梁某1、梁某2暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的犯罪事实有其两人的供述、证人证言、执法记录仪视频证实，证据之间相互印证，足以认定，梁某1的上诉意见不成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

2021年3月1日起,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式施行,修正案将《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第五款修改为:“暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。”

根据该条文的罪状表述,并未要求袭警行为需要造成具体的危害结果。实务界和学界对暴力程度目前还没有统一定论。一种观点认为,袭警罪属于行为犯,本罪的构成应要求造成法益侵害的结果,即要求暴力袭警行为对人民警察的执法行为造成实质性的妨害,一些地方公检法甚至将暴力袭警行为的追诉标准定为造成轻微伤以上危害后果。另一种观点认为,袭警行为是对国家法律秩序的危害,只要行为人对法益造成了现实的、紧迫的危险即可入罪,不需要一定具有实际损害结果。

笔者认为,袭警罪原则上不要求暴力达到一定程度,不宜机械地要求必须达到轻微伤以上,应该从其所保护法益保护原理及侵害法益的紧迫性来综合考量。

从袭警罪保护的法益上分析,立法者将本罪置于妨害公务罪的框架下作为其第五款,本罪的保护法益主要是国家正常管理秩序。虽然有观点认为其法益还包括人民警察的人身权利,但前者仍然是其保护的主要法益。如果要求对警察的人身安全造成实害,既然已经造成实害用故意伤害等罪名就足以保护,无须增设袭警罪。事实上,在袭警罪独立成罪之前,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》规定,人民法院、人民检察院和公安机关在办理此类案件时,要准确认识袭警行为对于国家法律秩序的严重危害,不能将袭警行为等同于一般的故意伤害行为,不能仅以造成民警身体伤害作为构成犯罪的标准,要综合考虑袭警行为的手段、方式以及对

①本书【法官后语】对相关法律问题涉及的法律法规等进行了时效性更新,下文不再对此进行提示。

执行职务的影响程度等因素，准确认定犯罪性质，从严追究刑事责任。据此，本罪入罪标准主要考察行为人是否以针对人民警察人身安全的暴力行为妨害了人民警察正常执行公务。

从危害结果上分析。如上所述，袭警罪保护的是双重法益，其危害后果不仅限于人身安全，还包括国家正常管理秩序。其危害后果涵盖的范围十分广泛，包括给民警造成伤害，妨害民警依法执行职务、财产损失、恶劣的社会影响等，行为人的袭警行为只需要对法益造成了现实的、紧迫的危险即可入罪，而不需要一定有实际损害结果。本案中，二名被告人使用汽油、镰刀等工具阻碍民警执法，在这种情况下，其实该行为阻止了公务的执行，也对民警的人身权益有现实和紧迫的危害。同时，二被告人的行为还造成多人围观、交通堵塞等的危害结果，认定为袭警罪是完全合理且应当的。

编写人：广西壮族自治区田东县人民法院 韦益万 李善瑛

暴力袭击配合人民警察执法的辅警人员行为的定性

—— 杨某某妨害公务案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省漳州市中级人民法院(2024)闽06刑终17号刑事判决书

2. 案由：妨害公务罪

【基本案情】

2023年10月3日12时许，被告人杨某某饮酒后驾驶1辆无牌照电动二轮轻便摩托车，行经事发路段时，与沈某某驾驶的轻型货车发生碰撞。公安机关

6 中国法院2025年度案例·刑事案例一

接警后指派民警江某某、沈某某及辅警张某、胡某某等人赶往现场进行处置。民警要求杨某某进行酒精呼气测试，但杨某某拒不配合，并欲逃离现场，在场民警江某某、沈某某及辅警张某、胡某某上前对杨某某进行控制。其间，杨某某将张某绊倒，并用拳头殴打张某的头部，后杨某某被控制并被带回某派出所。

【案件焦点】

暴力袭击正在配合人民警察依法执行职务的警务辅助人员，其行为应如何定性。

【法院裁判要旨】

福建省诏安县人民法院经审理认为：被告人杨某某暴力袭击正在配合人民警察依法执行职务的辅警，以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪，应予刑事处罚。

在本案中，被告人杨某某暴力袭击的对象是正在配合人民警察依法执行职务的辅警，而不是人民警察，其行为不属于“暴力袭击正在依法执行职务的人民警察”，故被告人杨某某的行为，不宜认定为袭警罪。但是，作为未列入国家机关编制的辅警，虽不具备执法主体资格，不能直接参与公安执法工作，但作为警务辅助人员，在公安民警的指挥和监督下开展辅助性工作，应视为在国家机关中从事公务的人员。被告人杨某某暴力袭击正在配合人民警察依法执行职务的警务辅助人员，以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的规定，构成妨害公务罪。被告人杨某某虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，又当庭认罪认罚，可以从轻处罚。福建省诏安县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十五条第一款第二项规定，判决：

被告人杨某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月。

一审宣判后，某检察院提起抗诉。

福建省漳州市中级人民法院经审理认为：原审被告人杨某某暴力袭击正在配合人民警察依法执行职务的警务辅助人员，以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。福建省漳州市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第一项规定，裁定：

驳回抗诉，维持原判。

【法官后语】

2021年3月1日，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》新增了袭警罪。实践中，对暴力袭击界定、辅警地位、罪与非罪、此罪与彼罪等问题存在诸多争议。2025年1月15日发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理袭警刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《袭警解释》)，对此作了系统性规范。

一、袭警罪与妨害公务罪的区分

在暴力袭警案件中，如何区分袭警罪与妨害公务罪，是司法实务中最核心的争议点，可从行为对象、暴力程度、主观故等方面予以判断、区分。

1. 从行为对象看，袭警罪仅限于针对正在依法执行职务的人民警察，包括治安警察、交通警察、司法警察等各类警察。而妨害公务罪的行为对象外延更宽，除包含人民警察外，还包含了其他国家机关工作人员，如辅警等。

2. 从暴力程度看，袭警罪要求暴力袭击，需具备突然性、攻击性及危害性，强调的是直接攻击警察人身，或实施足以危及警察安全的行为。根据《袭警解释》的规定，针对民警的人身攻击行为，须满足造成轻微伤以上后果；针对警务车辆、警械等装备的暴力袭击，须达到足以危及人身安全的程度。同时，《袭警解释》还将不属于暴力袭击的情形明确排除在袭警罪的打击范围之外。根据该解释第一条第二款，以下三种情形不构成袭警罪：一是轻微肢体冲突；二是危害不大的一般性抗拒行为；三是言语攻击行为。妨害公务罪行为范围较广，可包含暴力、威胁或其他阻碍手段。以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作

8 中国法院2025年度案例·刑事案例一

人员依法执行职务，暴力、威胁是手段、方式，阻碍是结果、目的。暴力、威胁的对象没有限制，不仅包括直接针对国家机关工作人员人身，也包括对与国家机关工作人员依法执行职务有关的人、物实施暴力、威胁，以达到阻碍国家机关工作人员依法执行职务的目的。

从体系解释的角度来看，立法将袭警罪与妨害公务罪放在一个条文中规范，作出暴力袭击与暴力阻碍两种不同表述，体现了两罪对于暴力性质与程度的不同要求。即袭警罪的暴力性质侧重于攻击，妨害公务罪的暴力侧重于阻碍，袭警罪的暴力程度明显大于妨害公务的暴力程度，否则也无须将原本属于妨害公务的行为作为加重情形升级为独立罪名。

3. 从主观上看，袭警罪只能是故意，且系直接故意；而妨害公务罪，是以阻碍国家机关工作人员执行职务为目的，其主观故意包括故意和过失。

4. 从处罚上看，袭警罪的处罚更重，根据刑法第二百七十七条第一款规定，妨害公务罪一般判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。而袭警罪，严重的可判处三年以上七年以下有期徒刑。

二、暴力袭击辅警行为的定性

实践中，警务辅助人员，是指不具有人民警察身份的人员，主要包括文职、辅警两类从事警务辅助工作的人员；辅警在公安机关及其人民警察的指挥和监督下，开展治安巡逻和安全防范宣传教育等职责。警务辅助人员不得单独执法。

司法实务中，可能存在以下三种情况。

1. 暴力袭击配合人民警察执行职务的辅警，其行为构成妨害公务罪。

首先，配合人民警察执行职务的辅警，应视为国家机关工作人员。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》规定，在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，或者虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，有渎职行为，构成犯罪的，依照刑法关于渎职罪的规定追究刑事责任。渎职罪的主体均为国家机关工作人员，故可以认为该解

释系为对“国家机关工作人员”的解释。配合人民警察执行职务的辅警，虽未列入公安机关编制，但在公安机关及其人民警察指挥和监督下开展工作，行为后果由公安机关承担，依据前述规定，亦应视为国家机关工作人员。

其次，暴力袭击配合人民警察执行职务的辅警，属于暴力阻碍人民警察执行职务的一种方式。辅警在人民警察的指挥和监督下开展工作，其所从事的工作虽是辅助的，但也是属于公安机关人民警察执行职务的一部分。行为人暴力袭击辅警，实质上也阻碍了公安机关人民警察依法执行职务。

综上，暴力袭击配合人民警察开展工作的辅警，本身就是以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为依法构成妨害公务罪。《袭警解释》第八条，也明确“暴力袭击正在依法配合人民警察执行职务的警务辅助人员的，不构成袭警罪；符合刑法第二百七十七条第一款规定的，以妨害公务罪定罪处罚”。

2. 同时暴力袭击人民警察和正在配合人民警察开展工作的辅警的，按照吸收犯原理处理，以袭警罪从重处罚。

吸收犯，是指数个行为之间存在吸收关系，一个行为吸收其他行为，仅按照吸收之罪处理的情形。通说认为，吸收犯包括完成罪吸收未完成罪，主行为吸收从行为，实行行为吸收教唆、帮助行为。同时暴力袭击公安机关人民警察和正在配合公安机关人民警察开展工作的辅警，虽然分别针对公安机关人民警察和辅警实施袭击行为，但两个行为之间存在相同的故意，都是为了阻止、排除对方执行职务，可以按照吸收犯原理处理，认定袭警罪一罪从重处罚，不实行数罪并罚。《袭警解释》第八条第二款规定，亦持本观点。

3. 暴力袭击单独执行职务辅警的，其行为不构成袭警罪、妨害公务罪。

鉴于警务辅助人员不得单独执法，未被赋予单独行使与公安机关执法活动的主体资格，在这种情形下，辅警单独执行职务，因缺乏一般职务权限和具体职务权限，不具有合法性，属于违法执法，行为人对其暴力袭击的，不构成袭警罪，也不构成妨害公务罪。只能根据具体伤情，视情给予行为人治安处罚，若构成故意伤害罪、故意杀人罪的，依照相关罪名定罪处理。

采用银行卡挂失或注销的方式转移卡内资金的定性

——李某盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省台州市中级人民法院(2024)浙10刑终48号刑事裁定书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

被告人李某系某贸易公司的法定代表人兼自然人独资股东。2022年4月1日，被告人李某与被害人陈某某签订转让运营合同，将该公司名下的某某商务平台五年运营权以120000元人民币的价格转让给陈某某，注册平台时使用的其名下的某银行的银行卡同时交付给陈某某，并约定不使用该卡内资金，被害人陈某某拿到银行卡后更改密码并使用。2022年6月至2023年1月18日，被告人李某多次利用绑定该银行卡的微信、支付宝账户无须输入密码的漏洞，秘密窃取该银行卡内陈某某经营所得的货款共计107949.19元。其间，陈某某发现卡内金额异常减少向被告人李某催讨，后双方同意将剩余平台租金20000元从中抵扣。2023年1月17日，陈某某因上述银行卡出现异常，要求被告李某配合前往银行办理手续并将卡内款项转至谢某某账户。2023年1月19日，被告人李某通过注销银行卡的方式将该账户内陈某某的1127694.61元货款转至赵某某账户。

【案件焦点】

行为人采用银行卡挂失或注销的方式转移卡内资金行为的定性。

【法院裁判要旨】

浙江省温岭市人民法院经审理认为：被告人李某作为银行卡账户的开户人，将银行卡交付给陈某某使用，双方约定李某不使用卡内资金，实质上李某已将银行卡账户资金的占有、使用权让渡给了陈某某，陈某某成为账户内资金的占有人，李某亦主观上明知银行卡里的资金系陈某某所有；陈某某作为该卡内资金的实际占有人和使用权人，重新设置密码在于排除李某对卡内资金的控制和支配，亦表明陈某某并未将卡内资金交由李某保管控制，二人之间不存在代为保管的关系。因此，前期(2022年6月至2023年1月18日)被告人李某以其微信、支付宝账户绑定银行卡的漏洞截留账户内资金，秘密将账户内资金非法转为自己占有的行为，应构成盗窃罪。后续(2023年1月17日)在银行卡出现取款异常时，被害人陈某某迫于条件同意被告人注销(挂失)银行卡，但明确指示被告人注销(挂失)后将原卡内资金转至其指定账户，并多次询问、催促被告人办理，陈某某只同意李某通过注销(挂失)协助办理银行转账到指定账户，从未作出委托李某代为保管卡内资金的意思表示，故生效裁判认为，李某具有非法占有他人财物的故意，事先预谋非法取得财物，通过注销(挂失)方式实施了秘密窃取他人财物，并实现了转移占有，被告人李某于2023年1月19日实施的行为亦构成盗窃罪。综上，被告人李某的相应行为均构成盗窃罪。

浙江省温岭市人民法院经审理认为：被告人李某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条之规定，作出如下判决：

一、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币14万元；

二、责令被告人李某退赔被害人陈某某人民币1215643.8元。

一审宣判后，李某提出上诉。

浙江省台州市中级人民法院经审理认为：原判事实清楚，证据确实充分，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要争议焦点在于被告人李某通过注销(挂失)银行卡的方式将卡内资金转移的行为构成盗窃罪还是侵占罪。侵占罪和盗窃罪的主要区别在于,侵占罪是行为人将自己占有的财物变为不法所有,而盗窃罪则是通过破坏他人对财物的占有以实现不法占有。由此,对财物占有的判断,即所涉财物是否属于他人占有的财物,是区分盗窃罪与侵占罪的关键所在。因此,认定案涉银行卡内的资金占有权属于谁对于本案的定性具有重要意义。

具体到本案,被告人李某作为银行卡账户的开户人,将银行卡交付给陈某某使用,双方约定李某不使用卡内资金,实质上李某已将银行卡账户资金的占有、使用权让渡给了陈某某,陈某某成为账户内资金的占有人,李某亦主观上明知银行卡里的资金系陈某某所有;陈某某作为该卡内资金的实际占有人和使用权人,重新设置密码在于排除李某对卡内资金的控制和支配,亦表明陈某某并未将卡内资金交由李某保管控制,二人之间不存在代为保管的关系。

值得注意的是,注销银行卡后被告人李某是否为陈某某代为保管银行卡内资金。首先,保管成立的前提条件是双方有保管的合意,对财物的保管要达成一致的意思表示。在银行卡出现取款异常时,被害人陈某某迫于条件同意被告人李某注销(挂失)银行卡,但明确指示被告人注销(挂失)后将原卡内资金转至其指定账户,据此可知陈某某只同意李某通过注销(挂失)协助办理银行转账到指定账户,从未作出委托李某代为保管卡内资金的意思表示,且李某对此亦是明知的。其次,李某的“短暂占有”行为不能成立代为保管。代为保管系合法占有、持续稳定占有。银行在办理注销(挂失)后,暂时会把资金留在柜台,随后会根据提供的转账账户进行转账。本案中,基于陈某某的意思表示,李某无论从法律上,还是从双方合意上,都无权控制支配卡内资金转到指定账户之外的账户上。在注销(挂失)银行卡到转账的过程中,李某事实上的控制状态是极为短暂的,不能因为一时地接触到财物就成立代为保管。综上,根据主客观相一致原则,本案不能成立代为保管。

编写人:浙江省温岭市人民法院 黄璐坤

“吃空饷”型职务侵占犯罪的数额认定问题

—— 胡某某等职务侵占案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市海沧区人民法院(2023)闽0205刑初382号刑事判决书

2. 案由：职务侵占罪

【基本案情】

胡某某在担任被害单位甲公司制造部班长期间，发现公司考勤漏洞，后利用其人工登记员工考勤记录、负责员工辞职事宜的职务便利，骗取甲公司发放的工资、年终奖、医社保等。具体如下：

1. 2019年11月15日，游某某经胡某某安排办理入职手续后未实际上班，后胡某某持游某某的上班考勤卡、工资银行卡，每日代游某某打考勤卡，并人工登记游某某的考勤记录。2021年10月1日起，胡某某雇佣杨某某每日代打上述考勤卡至2023年5月，并人工登记游某某的考勤记录。三人合伙伪造游某某上班假象，造成甲公司含税费、伙食费等实际损失27.7万余元，其中2021年10月之后的实际损失12.1万余元。由此，胡某某骗得公司发放的工资、年终奖23.7万余元，后其支付1.9万元给杨某某作为报酬，游某某骗得公司发放的医社保3万余元。

2. 2021年10月1日，陈某某(另案处理)向担任班长的胡某某提出离职申请，胡某某提议由其代打卡，共同骗取公司钱款。陈某某同意并交付上班考勤卡、工资银行卡。后胡某某每日代打考勤卡、人工登记考勤记录至2023年5

14 中国法院2025年度案例·刑事案例一

月，伪造陈某某上班假象，造成甲公司含税费、伙食费等实际损失12万余元。由此，胡某某实际骗得公司发放的工资、年终奖10万余元，陈某某骗得公司发放的医社保1.6万余元。

2023年7月17日，游某某经电话通知主动配合公安机关调查，但第一次讯问未如实供述上述犯罪事实，后如实供述上述犯罪事实。杨某某、胡某某分别于2023年7月20日、7月25日自行投案，归案后均能如实供述上述犯罪事实。胡某某、游某某共同赔偿甲公司经济损失人民币37.9万余元，杨某某赔偿甲公司经济损失1.9万元，尚未取得谅解。

【案件焦点】

通过挂名取酬的“吃空饷”方式实施职务侵占犯罪的，除公司直接支付“劳动者”的工资、年终奖外，五险一金等保障性待遇，以及公司代扣代缴的税费、伙食费、工会会费等费用是否应当计入侵占的犯罪数额。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区人民法院经审理认为：胡某某利用职务上的便利，伙同被告人游某某、杨某某将甲公司的财物非法占为己有，其中胡某某参与的犯罪数额为398275.97元，游某某参与的犯罪数额为277114.92元，杨某某参与的犯罪数额为121568.47元，均属数额较大，三人行为均已构成职务侵占罪。本案系共同犯罪。胡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。游某某、杨某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。胡某某、杨某某均系自首，游某某系坦白，依法均可以从轻处罚。三被告人已共同赔付被害单位的经济损失，可以酌情从轻处罚。三被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。综合考虑三被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和监管条件，认为对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。据此，判决如下：

一、胡某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；

二、游某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币5000元；

三、杨某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。职务侵占罪系数额犯，成立该犯罪应满足侵占数额较大的构成要件。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条的规定，职务侵占罪的起刑点为受贿罪数额标准的2倍，即6万元。在认定职务侵占犯罪数额时，应以被害单位被侵占的财物数额，即以案发时被害单位实际受到的损失数额进行认定。

本案是典型的以挂名取酬方式“吃空饷”的职务侵占犯罪。被告人胡某某利用其考勤管理的职务便利，通过代打卡的方式伪造未实际提供劳务的“劳动者”上班的假象，从而非法获取公司支付的劳动报酬。通过此犯罪行为，被害单位实际受到的损失可能包括以下范畴：

1. 工资、奖金等劳动报酬。劳动报酬由被害单位直接向“劳动者”发放，系犯罪行为人可以直接获取的违法所得，故工资、奖金应当计入犯罪数额。实务中存在挂名取酬被其他劳动者发现后，犯罪行为人为隐瞒罪行利用职权额外向其他劳动者发放加班费等报酬的情形，此时应视为系犯罪行为人实施犯罪支出的犯罪成本，且同样给被害单位造成了额外的经济损失，故应当计入职务侵占数额。

2. “五险一金”等保障性待遇。根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》的规定，用人单位有义务为职工缴纳，并代职工扣缴其个人应缴纳的“五险一金”费用。保障性待遇虽未直接支付给“劳动者”，但系由犯罪行为人实际控制且能够折算为货币的财产性权益，故应当计入犯罪数

额。对于犯罪行为人非法获取“五险一金”等保障性待遇的后续处置，除刑事上的退赃退赔问题外，在行政层面应当确认对应挂名劳动者因该犯罪行为获取的保障性待遇自始无效，以此确保任何人不得从犯罪行为中获利。

3. 个人所得税等代扣代缴费用。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国个人所得税法》等法律规定，具有应税所得的居民个人应依法缴纳个人所得税。个人所得税等费用系劳动者领取薪酬必须承担的税费。代扣代缴仅是个人所得税缴纳的一种方式，并不影响个人所得税属于劳动者领薪应承担税费的性质。在“吃空饷”型职务侵占中，单位代扣代缴费用是犯罪行为人获取非法利益要承担的必要费用，在此应视为犯罪成本，同样应当计入职务侵占数额中。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 张晨玮 苏容

以管教为名长时间频繁暴力殴打 未成年子女致死的行为定性方法

—— 王某、徐某故意伤害案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市高级人民法院(2024)沪刑终30号刑事裁定书

2. 案由：故意伤害罪

【基本案情】

被害人王某某长期在河南省与其祖父祖母共同生活。2022年8月底，王某某(十周岁)来到上海市随父亲即被告人王某和继母即被告人徐某共同生活，

就读于某小学。同年12月中旬，学校改由线上教学。2023年1月上旬至2月12日，待业在家的徐某时常向王某反映王某某学习不好、习惯不好、难以管教等情况，并杜撰班主任反映王某某存在上课注意力不集中、语文作业正确率差以及偷拿同学物品等问题。在上述期间内，王某、徐某以管教为由频繁采用拳打脚踢的方式或使用戒尺、木棍、钢管等工具对王某某的头面部、躯干以及四肢进行暴力殴打，还采用跪搓衣板、站在凳子上罚站、不许睡觉等方式对王某某进行体罚。同年2月7日，徐某带王某某就医，在医生告知要进一步做检查和治疗的情况下，徐某以次日会带王某某去熟悉医生处治疗为由拒绝，仅要求做伤口清创缝合及包扎。同年2月12日起，王某某出现大小便失禁并卧床不起，直至同月16日10时30分许，徐某发现王某某呼之不应，怀疑死亡。当日12时30分许，王某、徐某将王某某送至医院，送医时王某某已无生命体征。同日，民警将王某、徐某抓获归案，王某到案后如实供述了主要犯罪事实，徐某到案后仅如实供述了部分犯罪事实。经鉴定，被害人王某某系遭钝性外力反复作用致全身大面积皮肤损伤，引起皮下组织感染、坏死并继发间质性肺炎及心肌炎等，终致多器官功能障碍死亡。经司法鉴定，王某、徐某具有完全刑事责任能力。在法院审理期间，徐某的亲属向法院提交人民币17万元作为代徐某赔偿附带民事诉讼原告人的款项。

【案件焦点】

本案被告人的行为应认定为虐待罪还是故意伤害罪。

【法院裁判要旨】

上海市第一中级人民法院经审理认为：被告人王某、徐某主观上明知实施暴力殴打会对被害人身体健康造成伤害，仍长时间持续频繁暴力殴打被害人，在被害人头面部大面积淤青、肿胀，腿伤血流不止等肉眼可见的明显伤势下，依然继续殴打，二人的行为明显有别于虐待罪中的软暴力或轻暴力等一般暴力行为，已经超出追求肉体和精神摧残的虐待故意范畴，徐某殴打被害人的暴力程度虽未及王某，但亦有持戒尺、木棍等工具殴打被害人，且有挑唆王某殴打

被害人的行为，故二人均应认定为具有伤害被害人的故意；二人客观上使用戒尺、木棍、钢管等工具实施暴力，殴打频次频繁，殴打部位遍布被害人全身并伤及头面部等要害部位，殴打力度致戒尺、木棍断裂，殴打后果造成被害人死亡，作案手段残忍，暴力程度较强，鉴于二人殴打被害人并非积极追求被害人死亡结果，故王某、徐某的行为均已构成故意伤害罪，且系共同犯罪。王某、徐某作为王某某的父亲和继母，对王某某负有监护义务和照护职责，二人非但未尽相应职责，反而以管教为名，在长达一个多月时间内，频繁采用拳打脚踢或使用戒尺、木棍、钢管等工具对被害人肆意暴力殴打，在带被害人就医，医生要求进一步做检查和治疗的情况下拒绝治疗，在被害人卧床不起、大小便失禁情况下仍听之任之，放任被害人重伤乃至死亡后果的发生。故二人犯罪故意明显，犯罪手段残忍，犯罪情节恶劣，犯罪后果极其严重，依法应予严惩。综合二人在暴力程度上的区别及在共同犯罪中的地位、作用等，对二人量刑时予以区分；鉴于王某到案后能如实供述主要犯罪事实，对其判处死刑，可不立即执行。被告人王某、徐某的犯罪行为造成了附带民事诉讼原告人的经济损失，依法应当承担民事赔偿责任。上海市第一中级人民法院判决：

一、被告人王某犯故意伤害罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；

二、被告人徐某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年；

三、扣押在案的作案工具予以没收；

四、被告人王某、徐某赔偿附带民事诉讼原告人陈某人民币76098元。

一审宣判后，王某、徐某对刑事判决部分提出上诉。

上海市高级人民法院经审理同意一审法院的裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

对未成年子女长时间频繁实施暴力殴打的行为定性，主要涉及故意伤害罪与虐待罪的区分与认定。故应综合全案证据情况，以故意伤害罪与虐待罪的构罪要件区分为基础，围绕案件客观事实基础和被害人死亡结果的法医学归因，

以主观故意审查、客观行为评价的双向审查路径搭建认定框架，并通过主客观要件的交叉验证，实现此类案件的准确定性。具体分析如下。

一、主观要件认定方法：以故意伤害罪与虐待罪主观故意形态的实质区分为路径

主观明知认定属于事实认定，需以行为人的客观行为认定主观意思。故意伤害罪的主观要件在于行为人明知其暴力行为可能导致重伤或死亡结果，仍对伤害结果持积极追求或放任态度，而虐待罪则以控制、折磨为目的，追求被害人肉体和精神上的痛苦，对被害人的重伤或死亡结果仅存在过失。对未成年子女暴力管教涉刑案件因其“以管教为名”的案件特点，多呈现施暴行为经常性、持续性、反复性的行为特征，故应着重审查行为人的工具使用、击打部位、施暴行为、过程及事后态度等方面，具体可从行为人是否使用钝器、锐器等致命工具，是否击打头面部、胸腹部等要害部位，施暴过程中有无因被害人伤情恶化而停止，有无故意隐瞒伤情拖延救治等能够体现主观心态的客观事实着手，进行综合判断。

本案中，首先，从工具使用、击打部位看，王某、徐某均有频繁拳打脚踢及持戒尺、木棍、钢管等工具殴打被害人的行为，且殴打部位遍布全身，亦均有针对头面部等要害部位进行殴打，王、徐作为心智健全的成年人，应认定二人对其暴力殴打行为会对被害人身体健康造成伤害系明知。其次，从施暴过程及事后态度看，徐某虽在发现被害人腿部流血不止后，有带被害人就医的行为，但却以次日会带被害人去熟悉医生处治疗为由拒绝医生进一步检查与治疗的要求，仅做伤口清创缝合。从医院回家当晚，王某不顾被害人刚从医院缝合伤口回来，依然持戒尺、钢管等工具暴力殴打被害人，且二人在此后仍每日对被害人实施殴打。故王某、徐某的暴力殴打行为显然已经超出了追求肉体和精神摧残的虐待故意范畴，应认定为主观上具有故意伤害的故意；在被害人已卧床不起、大小便失禁情况下仍听之任之，足见二人对被害人重伤乃至死亡结果持放任态度。

二、客观行为评价规则：以实施的暴力手段与方式、暴力程度及与伤害结果间的因果关系判断为要点

从客观方面的构罪要件看，暴力管教类案件中故意伤害罪的行为模式多表现为持凶器实施暴力，暴力行为呈现手段残忍，暴力程度较强的特征，且暴力行为与被害人重伤或者死亡结果具有直接因果关系，而虐待罪则表现为长期或者多次实施虐待行为，逐渐造成被害人身体损害，重伤或死亡结果系长期虐待间接导致，体现出累积性因果关系特征。

本案中，从暴力行为看，作案工具从木质戒尺到不易折断的硬质树脂材质戒尺，从木棍到粗钢管，作案工具逐步升级，监控视频反映二人殴打被害人的持续时间及暴力程度亦不断上升，足见二人殴打被害人的暴力手段残忍，暴力程度较强。从危害后果看，尸检报告证明被害人的体表损伤形态多样，全身大面积皮肤损伤，引起皮下组织感染、坏死并继发间质性肺炎及心肌炎等，终致多器官功能障碍死亡，与被害人遭王某、徐某用戒尺、木棍、钢管等物持续一个多月长时间、反复暴力殴打相吻合，证明被害人死亡与王某、徐某的长期暴力殴打行为具有直接因果关系，并无其他因素介入。

综上，行为定性应秉持主客观相统一的认定原则，在主客观因素交叉验证下依法准确认定。本案中，王某、徐某主观上具有故意伤害的故意，客观上使用戒尺、木棍、钢管等工具，殴打频次频繁，殴打部位遍布被害人全身并伤及头面部等要害部位，击打力度致戒尺、木棍断裂，伤害后果造成被害人死亡的严重后果，作案手段残忍，暴力程度较强，鉴于二人殴打被害人并非积极追求被害人死亡结果，故综合上述主客观因素，应认定王某、徐某犯故意伤害罪。

编写人：上海市第一中级人民法院 王骥

故意犯罪中直接故意与间接故意的认定

—— 于甲故意伤害案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省高青县人民法院(2023)鲁0322刑初81号刑事判决书

2. 案由：故意伤害罪

【基本案情】

被告人于甲与被害人隋某某原系多年好友，被告人于甲长期在外打工，隋某某与被告人之妻于乙发生不正当男女关系。于甲得知后于2022年12月12日19时邀请隋某某夫妻到其家中商议解决此事。隋某某不想让其妻子得知此事，便自行前往。在于甲家吃饭喝酒的过程中，隋某某指责于甲对于乙关心不够等，于甲心生不满，去厨房将菜刀藏至腋下，欲报复隋某某，后因思想矛盾，携带菜刀进入厕所。在厕所时于甲发现隋某某与于乙还在悄悄说话，情绪失控，趁隋某某不备，使用菜刀将背向自己坐着的隋某某头部、颈部砍伤。隋某某和于乙将菜刀夺下。后于甲让其妻子于乙拿衣服给隋某某包扎止血，于乙拨打急救电话，并陪同隋某某出门就医。于甲在家中拨打报警电话。经鉴定，被害人隋某某的伤情系轻伤二级。

被告人于甲案发后主动报警，到案后如实供述主要犯罪事实。在诉讼过程中，被告人于甲已赔偿被害人隋某某经济损失，并取得谅解。隋某某于2023年5月27日向法院提出撤诉申请，法院于同年5月31日裁定准许撤回起诉。

【案件焦点】

在故意犯罪中，对于被告人具有直接故意还是间接故意的认定。

【法院裁判要旨】

山东省高青县人民法院经审理认为：关于本案定性问题，经查，本案系因感情纠纷引发，被告人于甲与被害人隋某某原系朋友关系，本案案发前二人仍然关系要好。从犯罪动机来看，虽被告人于甲之妻与被害人存在不正当男女关系，被告人知晓后并未产生杀人之念，通过在案证据，亦能证实被告人于甲得知此事后的第一反应是想通过对话的方式解决；于甲已决定与于乙离婚，其邀请被害人吃饭的目的是问清原由，案发前的整个过程，双方情绪稳定，无争吵等过激行为。而且，被告人亦邀请了被害人的妻子吃饭，被害人妻子系事外之人，对于其丈夫出轨于乙之事并不知情，若被告人于甲预谋杀人，完全没有必要多此一举，作案时多一人在场，就多一分失手的风险，此举不符合常情常理。从作案时机来看，双方系在被告人家中吃饭，共有被告人于甲、妻子于乙、被害人隋某某三人。其间，被告人妻子因事外出二次，该两段时间内于甲与被害人系独处一室的状态，对于甲来说应是行凶的最佳时机，且无他人阻挠、干扰，得手率最高，但于甲并未实施犯罪行为。对于犯罪工具的准备，于甲使用的系家用菜刀，虽刀具的杀伤力巨大，但其并非刻意准备足以剥夺他人生命的致命性工具，而是在受到刺激后偶然准备。再者，被告人于甲将被害人砍伤后，被摁倒在地，于甲完全有机会、有能力继续实施犯罪行为。在发现被害人流血后让其妻子于乙止血，亦未阻止于乙拨打急救电话及陪同被害人就医。虽然被告人于甲使用菜刀砍他人头部、颈部的行为严重危及被害人的生命安全，该危害行为具有剥夺他人生命的高度危险性，但对于死亡结果的发生存在不确定性，并非必然会导致他人死亡的危害后果，故被告人不具有积极追求被害人死亡的直接故意。

被告人不顾他人死伤，持刀行凶，不计后果的行为，应认定为间接故意。间接故意犯罪系主观上放任危害结果发生，危害结果实际发生是成立间接故意犯罪的必要条件，故间接故意杀人，客观要件上需出现被害人死亡的危害结果，

而本案被害人的损害程度系轻伤二级，故，对被告人以故意伤害罪定罪处罚符合主客观相一致的认定原则。

关于被告人的辩护人所持“被害人存在严重过错”的辩护意见，经查，被告人于甲与被害人隋某某原本为关系较好的朋友。被害人的行为违背公序良俗，对本案的发生及矛盾的激化负有直接责任，应认定被害人具有明显过错。

综上，被告人于甲故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应予刑罚。山东省高青县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条、第六十一条之规定，作出如下判决：

一、被告人于甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；

二、作案工具菜刀一把，予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案主要涉及故意犯罪下对于“直接故意”与“间接故意”的区分及认定问题。《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第十四条对故意犯罪有明确的规定，将行为人的主观故意按照认识因素和意识因素分为直接故意与间接故意。根据通说观点，间接故意不存在未遂形态，而是在客观上要求危害结果的实际发生。即若行为人实施的危害行为未造成危害结果，则不能以此来定罪量刑。因此，直接故意与间接故意的区分直接影响到对于行为人犯罪行为的定性，在量刑方面，直接故意的行为人主观恶性较大。直接故意与间接故意在认识因素上，均要求行为人明知自己的行为会导致危害结果的发生，若行为人认为必然会发生危害结果，而实施危害行为，就算该危害结果实际上为可能发生，因行为人主观上认定必然发生而实施的危害行为，能够证实其具有希望或者追求结果发生的直接故意。直接故意在意志因素上要求行为人积极追求结果的发生，而间接故意则要求持放任态度，即听之任之。

危害行为系主观意志的外化表现，但不同的主观意志也可能外化为相同的行为，因此对于行为的定性需注重分析行为人的主观意志。本案中，争议的焦

点问题在于被告人于甲在情绪失控后，使用菜刀将隋某某头部、颈部砍伤的危害行为如何评价，也即被告人于甲主观意志方面对于危害结果的发生是积极追求还是放任态度。现就本案被告人于甲的犯罪行为，结合在案证据进行分析评判。

一、直接故意的认定

直接故意杀人，要求行为人主观上具有非法剥夺他人生命权的故意，应是希望并积极追求危害结果的发生。本案中，从犯罪动机来看，虽被告人于甲之妻与被害人存在不正当男女关系，被告人知晓后并未产生杀人之念，通过在案证据，亦能证实被告人于甲得知此事后的第一反应是想通过对话的方式解决，于甲已决定与于乙离婚，其邀请被害人吃饭的目的是想问清原由，案发前的整个过程，双方情绪稳定，无争吵等过激行为。而且，被告人亦邀请了被害人的妻子吃饭，若被告人于甲预谋杀人，完全没有必要多此一举，作案时多一人在场，不符合常情常理。从作案时机来看，双方系在被告人家中吃饭，共有被告人于甲、妻子于乙、被害人隋某某三人。其间，被告人妻子因事外出二次，这段时间对于甲来说应是行凶的最佳时机，但于甲并未实施犯罪行为。对于犯罪工具的准备，于甲使用的系家用菜刀，虽刀具的杀伤力巨大，但其并非刻意准备足以剥夺他人生命的致命性工具。再者，被告人于甲将被害人砍伤后，被摁倒在地，于甲完全有机会、有能力继续实施犯罪行为。在发现被害人流血后让其妻子于乙止血，亦未阻止于乙拨打急救电话及陪同被害人就医。虽然被告人于甲适用菜刀砍他人头部、颈部的行为严重危及被害人的生命安全，该危害行为具有剥夺他人生命的高度危险性，但对于死亡结果的发生存在不确定性，并非必然会导致他人死亡的危害后果。故被告人不具有积极追求被害人死亡的直接故意。

二、间接故意的认定

间接故意杀人，要求行为人主观上明知自己的行为可能会发生危害他人生命权的结果，仍然继续实施犯罪行为，放任该结果的发生。本案系因感情纠纷引发，被告人于甲与被害人隋某某原系关系较好的朋友关系。被告人于甲至厨房拿取菜刀时，并未在出厨房的第一时间伤害被害人，而是进入卫生间内，于

甲在主观上对于持刀行凶的危害后果有所顾忌，担心会造成被害人死亡的危害后果，于甲也并未认识到若拿刀砍被害人是否会必然导致被害人的死亡。被害人隋某某与被告人妻子于乙悄悄说话的行为刺激了被告人于甲，遂导致于甲情绪失控，激愤之下拿刀将被害人砍伤。被告人于甲不顾他人死伤，使用具有高度致害性的工具，不计后果地实施犯罪行为，对于被告人死亡与否的结果听之任之，主观上持放任态度，应认定为间接故意。

从另一个角度来说，在被告人主观意志无法查明的情况下，应按照存疑时有利于被告人的原则，根据现有证据，综合予以认定。

编写人：山东省高青县人民法院 韩超

对生产、销售有毒、有害食品犯罪中行为人对添加有毒、有害的非食品原料的主观明知推定，应综合行为人的认知能力、食品质量、进销渠道、产品价格等主客观因素进行

——周某等生产、销售有毒、有害食品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2024)浙11刑终16号刑事附带民事判决书

2. 案由：生产、销售有毒、有害食品罪

【基本案情】

2020年，被告人周某、安某先后安排周某1、张某1、张某2以呋塞米(利尿剂)、豆奶粉、香精、糊精、防腐剂等为原料生产制造加强版减肥药。同

时，安某雇佣他人将生产的加强版减肥药包装成“A牌”“B牌”减肥药，并通过微信销售给被告人周某2，周某2又通过各级代理即被告人罗某、施某、金某、杨某等人对外销售。

2020年10月至2022年7月，被告人周某、安某生产、销售减肥药数量共计166040粒，销售金额共计1438700元。经检测，从被告人安某经营的健康管理公司查获并扣押的“A牌压片糖果”（即“A牌”减肥药）“B牌植物果蔬压片糖果”（即“B牌”减肥药）以及从被告人周某2的放货仓库查获并扣押的“B牌植物果蔬压片糖果”均检测出呋塞米成分。

【案件焦点】

1. 呋塞米是否为有毒、有害的非食品原料；2. 关于被告人的主观明知如何认定。

【法院裁判要旨】

浙江省龙泉市人民法院经审理认为：被告人周某、安某在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，情节特别严重，其行为均已构成生产、销售有毒、有害的食品罪；被告人周某2、罗某、施某、金某、杨某销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，情节特别严重，其行为均已构成销售有毒、有害的食品罪。据此，以生产、销售有毒、有害食品罪，判处周某有期徒刑十一年，并处罚金人民币230万元；判处安某有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币200万元；以销售有毒、有害食品罪，判处周某2有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币430万元；判处罗某有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币275万元；判处施某有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币260万元；判处金某有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币20万元；判处杨某有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10万元。

一审宣判后，周某、安某、周某2、罗某、施某、金某提出上诉。

浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当。据此，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于呋塞米是否为有毒、有害的非食品原料以及被告人的主观明知如何认定。

一、呋塞米为有毒、有害的非食品原料

《中华人民共和国食品安全法》规定，生产经营的食品中不得添加药品。呋塞米为利尿剂，属于不得在生产经营的食品中添加的物质。鉴定意见证实呋塞米可导致电解质紊乱、泌尿系统功能紊乱等毒副作用，长期或者过量摄入，会对服用者的健康和生命安全造成危害，经丽水市市场监督管理局确认，应当认定呋塞米属于有毒、有害非食品原料。

二、被告人的主观明知如何认定

根据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，方才构成本罪。行为人主观上是否明知，是认定本罪的关键。

具体到本案，周某、安某作为生产者，安排他人以呋塞米、豆奶粉、香精、糊精、防腐剂等为原料生产制造减肥药，其主观明知可以直接认定。但周某2、罗某、施某、金某、杨某等人作为下级代理销售人员，其主观上只要明知可能是有毒、有害食品即可，不需要对毒害成分予以明确。而是否达到“明知可能是有毒、有害食品”，应当综合行为人的认知能力、食品质量、进货或者销售的渠道及价格等主、客观因素进行认定。周某2、罗某、施某均是销售减肥产品的经营者，应对减肥保健食品的药理、毒理作用有注意义务，并对是否可能非法添加物质具有审查注意义务。周某2、罗某、施某均知道普通版的减肥药产自广东，有检测合格证，而加强版减肥药产自山东，没有检测合格证，两种产品效果完全不同，但包装、价格却一样，三人作为销售减肥产品的经营者就应意识到加强版减肥药可能非法添加了有毒、有害物质。周某2本人的供述以及其与“某店”、罗某的微信聊天记录能够证实其于2020年10月就知道加强版减肥药添加有不好的成分，但认为利尿剂没有西布曲明（中枢神经抑制剂）严

重；罗某本人的供述以及其与周某2、施某的聊天记录能够证实其于2021年1月即明知销售的加强版减肥药添加了有毒、有害成分；施某本人的供述以及其与罗某、其他客户的微信聊天记录能够证实其在2021年6月销售加强版减肥药之前即怀疑该加强版减肥药含有不好的成分，在开始销售加强版减肥药时进行网络推广却不用加强版的，且销售案涉减肥药不久即有客户反映尿多等不良症状，足以证实其在2021年6月就对案涉减肥药添加了有毒、有害成分具有主观认知。

综上，在认定生产、销售有毒、有害食品罪时，要求行为人主观上必须“明知”，包括知道和应当知道，否则就是客观归罪。对行为人主观明知的推定，应综合行为人的认知能力、食品质量、进销渠道、产品价格等主客观因素进行盖然性判断。

编写人：浙江省龙泉市人民法院 周雷雷

利用网络棋牌APP（手机应用软件）在社交软件群内进行赌博活动的认定

—— 徐某赌博案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

辽宁省阜新市海州区人民法院（2023）辽0902刑初14号刑事判决书

2. 案由：赌博罪

【基本案情】

被告人徐某于2020年8月至2021年3月，在其家中利用“某APP”建立

群聊，并利用“某APP”开设麻将桌，并将房间号发到“某APP”群聊中，每满四人就可以开始赌博。赌博模式为打麻将，系统有分数来计算输赢。麻将一共四圈，参赌人员将结算分数发到徐某微信或者“某APP”群中。每分代表20元人民币，参赌人员中的输家将所输钱款通过微信转给徐某，徐某再将钱款发给赢家，后由同一桌次中的大赢家将40元桌费转给徐某。徐某在“某APP”开设房间购买房卡共花费4800元，开设房间2080次，徐某通过收取40元桌费共获利83200元，徐某纯获利78400元。

【案件焦点】

徐某利用棋牌类APP在社交软件群内进行赌博活动的行为应如何定性，是应认定开设赌场罪还是认定赌博罪。

【法院裁判要旨】

辽宁省阜新市海州区人民法院经审理认为：被告人徐某以营利为目的，利用手机APP软件为赌博人员开设房间，为参赌人员进行结算并从中获利，其行为已构成赌博罪，应以赌博罪追究其刑事责任。据此，以赌博罪判决：

被告人徐某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。上缴的全部违法所得予以没收，上缴国库。用于犯罪使用的手机及平板电脑予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

辽宁省阜新市海州区人民法院经审理认为：本案的争议焦点在于徐某的行为是应认定为开设赌场罪，还是赌博罪。

1. 对“某APP”的定性问题。该软件属于正常棋牌类游戏软件，设立初衷仅供大家娱乐消遣，不具有接受投注、支付结算等功能，不属于赌博性质软件，亦不属于赌博网站。而根据2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》），都只是采用了列举的方式规定了赌博网站的网络赌博形式，并未对

网络赌场的具体表现形式进行限制性规定。故被告人徐某利用此款APP进行赌博活动并不符合该规定中开设赌场的规定。

2. 为赌博活动设立的社交软件群组所形成的虚拟网络空间是否可以成为赌场的载体。随着信息网络的发展,赌博行为逐渐从线下实体场所发展到线上网络空间,许多人利用微信等社交软件建立群组,群主组织大家在聊天群组中进行下注、竞猜、开奖等行为或者通过往群组中发布网络链接或者游戏APP并让群成员按照一定规则进行游戏,并通过其制定的规则进行支付结算,完成赌博行为。无论是2005年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)还是2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的《意见》,都只是对利用赌博网站进行赌博的行为进行了列举,并未对其他利用网络进行的开设赌场行为进行规定,但是从审判实务的角度出发,现有案件中利用网络虚拟空间的赌博行为不单单依托赌博网站进行,还有更多其他形式存在,所以仅按照《解释》以及《意见》去定义是否属于开设赌场罪,不能顺应时代的发展,更对行为的定性存在偏颇,不能做到罪刑相适应。目前最高人民法院公布的指导性案例中明确了利用微信群组织赌博活动的行为认定为开设赌场,进一步证明了,赌场不仅仅是现实存在的特定物理空间,网络虚拟空间也可以成为赌场的载体。

3. 利用网络群组进行赌博行为,是否均构成开设赌场罪。“网络赌场”与“现实赌场”在本质上并无区别,仅仅是存在的载体不同而已,故“现实赌场”的特性与“网络赌场”是一致的,均以赌博为目的设立,开设赌场的行为人对赌场具有一定的控制性、经营性、管理性。本案中,被告人徐某设立此麻将群从主观目的看是因为其自身喜欢打手机麻将,此前其经常打麻将的群组解散了,随后该群中几个参与打手机麻将的群成员自行组织了新的聊天群组,方便几人继续玩手机麻将,其本人也经常参与群组中的麻将活动,故从其建立聊天群组的主观目的上看,并不是面向不特定人提供专门赌博的空间并“抽头渔利”。从客观行为上看,开设赌场的赌客具有不特定性,该案中,麻将群成员仅十几个人,较少,基本都是互相认识,或者部分是群成员拉进来进行手机麻将活动

的，人员组成相对固定且保持稳定，不具有自动吸引力；开设赌场者要对赌场有控制性、经营性和管理性。本案中的手机麻将群建立初期，均是由各群成员自行购买“房卡”进行麻将游戏房间建立，后来大家为了建立房间方便，就统一让其“建房”，每分需要支付的金额也不是其个人制定的，而是延续之前在别的麻将群的规则，大家约定俗成，并没有刻意强调及在群内发布。被告人徐某也并未对外发布该群的相关信息招募他人进行赌博活动，该聊天群组也没有相对规定的组织架构、人员分工及明确制定相关规则，故被告人缺乏对用于赌博活动的聊天群组的控制性、经营性和管理性，不能仅依据被告人有“抽头渔利”的行为就认定其属于开设赌场行为。综上，无论从被告人的主观目的和客观行为均不符合开设赌场罪，而是符合以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的赌博罪。

编写人：辽宁省阜新市海州区人民法院 李朋芮

买卖外汇型非法经营犯罪中违法性认识错误的审查与认定

—— 曹某某等非法经营案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院（2023）闽02刑终130号刑事裁定书

2. 案由：非法经营罪

【基本案情】

曹某某对外宣称其经营美元兑换人民币业务，邱某某、洪某某等人参与居中介紹获得报酬。2021年3月，曹某某将99张面值100美元的现钞与50叠其

购买的美元“样板钞”包装成50捆100美元面值的“样板钞”送至邱某某住处，作为向买家展示的美元“样板钞”。2021年4月，买家李某某经洪某某介绍联系到邱某某，欲购买500万美元现钞。双方在邱某某住处商谈并约定，以美元汇率下浮15%的价格交易（其中3%作为中间人的介绍费），李某某一次性支付35万元人民币作为查看美元现钞的定金，并展示人民币现金视频作为履约保证，三日内现场现金交易，邱某某以家中金属工艺品作为履约保证物。李某某支付部分定金10万元、发送视频后，至邱某某住处欲支付剩余部分定金，并查验500万元美元现钞实物，因发现箱子里放置的50捆美元每捆中只有上下两张是真钞，其余均是“样板钞”，认为邱某某等人实施诈骗，双方发生争执，均报警。民警至现场将邱某某抓获，现场查扣美元真钞99张、美元“样板钞”50叠。案发后，曹某某被公安机关抓获，洪某某接民警电话主动投案。邱某某配偶将李某某预付的人民币10万元定金送至侦查机关。随案移送曹某某、邱某某、洪某某手机各一部及邱某某用以担保交易的金色金属块。

被告人曹某某被公安机关抓获，侦查阶段拒不如实供述，直至审查起诉阶段才如实供述，被告人洪某某主动投案后如实供述，二被告人均认罪认罚。被告人邱某某到案后侦查阶段、审查逮捕阶段均如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段后，翻供不认罪，辩解其认为该美元交易是合法的，其被曹某某蒙骗误以为美元有合法来源、本案货币交易双方均具有合法手续，没有犯非法经营罪的主观故意。

【案件焦点】

买卖外汇型非法经营犯罪中，应当如何审查与认定犯罪行为人是否具有违法性认识错误，以及违法性认识错误是否影响非法经营罪的成立。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区人民法院经审理认为：买卖外汇型非法经营罪属于行政犯，即行为具有行政违法性，行为严重程度达到犯罪时需要承担刑事责任。因行政法规规定的公开性，主观认识不足或认识错误并不影响本罪的构成。因

此，被告人邱某某以其相信交易双方均具有合法手续无法对抗本案犯罪要件的构成。而本案的发生无论从交易主体、交易场所和交易形式，均无法得出交易具有合法性的结论，被告人邱某某抗辩的本案交易具有合法性亦不能成立。被告人曹某某、邱某某、洪某某三人违反国家规定，实施倒买倒卖外汇的非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，折合人民币数额达3282.45万元，其行为已构成非法经营罪，属情节特别严重。本案中，被告人已经着手实行犯罪因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。本案系共同犯罪，被告人曹某某对接美元卖家并借助邱某某、洪某某寻找美元买家，允诺一定报酬，发送交易流程、收取定金等，系交易的背后主导者，系主犯。被告人邱某某作为居间介绍人，负责提供场所与买家进行对接、提供“样板钞”展示，收取定金；被告人洪某某作为介绍人，将买家带至邱某某处并负责双方的对接；二人积极提供实质性帮助，系从犯，依法减轻处罚。被告人洪某某系自首，依法可以从轻处罚。被告人曹某某、洪某某认罪认罚，可以从宽处理。据此，判决如下：

一、被告人曹某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元；

二、被告人邱某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币5万元；

三、被告人洪某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4万元；

四、扣押在案的99张美元真钞及10万元人民币、其余美元样本钞、手机两部，依法予以没收；金色金属块一块发还邱某某、手机一部发还给曹某某。

一审宣判后，邱某某提出上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：上诉人邱某某、原审被告曹某某、洪某某违反国家规定，实施倒买倒卖外汇的非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，折合人民币数额达3282.45万元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。本案中，上诉人邱某某与原审被告曹某某、洪某某已经着手实行

犯罪因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。本案系共同犯罪，其中，被告人曹某某系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人邱某某、原审被告洪某某系从犯，依法予以减轻处罚。原审被告洪某某系自首，依法予以从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

非法经营罪是典型的行政犯，以违反国家行政法规中确定的禁止性规定为前提，行为程度达到情节严重构成犯罪的，对违法行为人依法追究刑事责任。因刑法规定的空白罪状、行政法的庞大复杂等原因，在非法经营犯罪中，行为人以其对相关行为的违法性认识不足、认识错误为抗辩的情况常见。具体到本案，被告人邱某某作为外汇交易的居间方，以其认为外汇交易双方具有合法手续、交易合法，其主观上无非法经营的犯罪故意为由提出无罪抗辩。针对此，本案从以下思路进行分析评判：

一是如何认定行为人是否存在违法性认识错误。行为人是否知道案涉交易不具有合法性，可以参考交易主体、场所、形式等综合判断。从交易主体上看，根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，个人从事外汇买卖等交易应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。居间人邱某某称其受诱骗认为案涉交易卖方曹某某系国家工作人员、买卖的美元系合法的国家储备钞，但曹某某提供的交易流程中无任何机构公章、用语亦不规范，案涉交易未公开宣传，而是经特定人居间形成，形式上遮遮掩掩。从交易场所上看，案涉交易商谈地点系在居间人邱某某家中，邱某某还另行提供私人物品向买方担保其有兑付美元的能力，而非直接向买方出具相关合法证明。从交易形式上看，本案例外汇交易价格的确定系由买卖双方协商后达成的，交易价格与当日市场化汇率有较大差距，超出外汇正常浮动范围，且通过现金兑付如此大标的额交易，明显系逃避银行监管。以上特征均可体现出买方并不具有合法兑换美元的资质、案

涉交易不具有合法性，居间人在此中积极促成、帮助交易，且收取高额介绍费，其抗辩相信本案交易具有合法性不予采信。

二是违法性认识错误是否影响行政犯的成立。若行为人确有违法性认识错误，且该违法性认识错误不可避免、无法克服，根据罪刑罚相适应原则及宽严相济刑事政策，应对其从轻、减轻甚至免除刑事处罚。基于行政法规的公开性，我们在认定时应更为审慎，重点审查对应行政法规的时效性、地域性、强制性、专业性等特征及行为人的认知能力。以本案外汇交易为例，我国对外汇实行强制管理制度，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖业务，都应当获得国家外汇管理部门的许可、取得相应业务资格，并在指定的场所进行交易。《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇，倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大，构成犯罪的，依法追究刑事责任。《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条第一款规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。以上法律法规能够体现出我国对私自交易外汇等行为明确禁止，且该国家政策具有长期性、普遍约束性特点，系一般公众能够认识、应当认识的。故行为人的违法性认识错误并不影响买卖外汇型非法经营罪的成立。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 芦絮 苏容

合同诈骗中行为人非法占有目的之司法认定

—— 曾某合同诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02刑终445号刑事裁定书

2. 案由：合同诈骗罪

【基本案情】

2021年12月，被告人曾某在身负高额债务且缺乏履约能力的情况下，以非法占有为目的，通过房产中介周某等人与被害人钟某达成购房协议，约定以人民币439万元的总价购买被害人钟某位于某小区X×号XX室的房产。为顺利签订房产买卖协议，被告人曾某对被害人钟某隐瞒个人征信不良情况、谎称有亲戚任职某银行某支行行长可以帮助快速办理银行贷款。被告人曾某在支付10万元定金和40万元首付款后，谎称余款待向银行贷款后付清，骗取被害人钟某办理过户手续，将涉案房产过户至被告人曾某名下。2021年12月16日，被告人曾某继续以任职某银行某支行行长的亲戚已办妥贷款手续，无须钟某共同前往银行为由，骗取房产证取件单并领走房产证，并于同年12月24日将涉案房产典当抵押给典当公司借款人民币280万元。被告人曾某将房产典当抵押后，仍对被害人钟某谎称在办理银行贷款，也并未将借款用于支付购房尾款，而是用于偿还个人债务和开支等其他用途。

2021年12月29日，被害人钟某和被告人曾某达成调解协议，钟某向海沧区人民法院申请确认调解协议的效力，福建省厦门市海沧区人民法院于2022年

1月4日出具民事裁定书，确认双方达成的调解协议有效。因被告人曾某未按期还款，被害人钟某于2022年1月10日向福建省厦门市海沧区人民法院申请强制执行。2022年4月22日，因被告人曾某未归还典当公司借款，该公司向福建省厦门市海沧区人民法院申请强制执行，要求拍卖上述某小区××号××室房产。2022年6月27日，福建省厦门市海沧区人民法院依法拍卖上述房产，成交价为人民币3747723.2元，被害人钟某分配到人民币485561.7元。至案发，被害人钟某尚有售房款人民币3404438.3元未能收回。

2022年8月31日，被告人曾某在某小区××室被公安机关抓获。

【案件焦点】

被告人曾某的行为是否构成合同诈骗罪。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区人民法院经审理认为：被告人曾某的行为构成合同诈骗罪，具体理由在于：第一，被告人曾某在签订购房合同时不具备履约能力。被告人曾某在案发前已背负高额债务，且其个人征信记录不良无法从银行贷款；被告人曾某名下没有资产，缺乏稳定收入来源，其购房所需的定金及首付款系向他人借款，不具有购买涉案房产并履行房产买卖协议的能力。第二，被告人曾某在签订、履行购房合同过程中虚构事实、隐瞒真相。被告人曾某明知其个人征信不良，为骗取被害人信任从而签订购房合同，向被害人和中介提供未显示信用卡逾期的虚假个人征信报告，故意隐瞒其征信不良的情况；被告人曾某虚构有亲戚在银行任职行长可帮忙快速办理银行贷款，使被害人相信其有能力尽快支付剩余购房款；被告人曾某支付定金和首付款，部分履行购房合同义务，并以向银行办理抵押贷款为由骗取房产证；被告人曾某取得房产证后并未办理银行贷款，而是将房产抵押典当用于借款，并对被害人隐瞒抵押典当的事实。第三，被告人曾某没有履行支付剩余购房款的行为。被告人曾某通过典当抵押所借钱款并未用于支付剩余购房款，反而将钱款全部转移，用于个人还款和消费等，其主观上不具有履约意愿，客观上未实施履约行为，恶意挥霍钱款，给

被害人造成巨大经济损失。截至案发，被害人钟某尚有售房款人民币3404438.3元未能收回。综上，在案证据足以证明被告人曾某具有非法占有的目的，在签订、履行购房合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取被害人钟某财物，数额共计人民币3404438.3元，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项“没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的”之规定，构成合同诈骗罪。

法院认为，被告人曾某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币3404438.3元，其行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大。被告人曾某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款共计人民币260900元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控的罪名均成立。被告人曾某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人曾某对指控的诈骗罪认罪认罚，依法可从宽处罚。被害人钟某的经济损失已由生效民事裁定确定曾某的偿还义务，本案不再责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人曾某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑13年，并处罚金人民币23万元；

二、扣押在案的作案工具手机一部，依法予以没收；

三、责令被告人曾某退赔被害人郑某某经济损失人民币260900元。

一审宣判后，曾某提出上诉。

福建省厦门市中级人民法院同意一审法院裁判意见，并依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案裁判的难点在于如何认定被告人曾某行为的性质。一方面，从行为的

形式上看，被告人曾某与被害人钟某之间有签订房产买卖合同，并向被害人支付了首付款和定金；另一方面，从行为的结果上看，被告人曾某未支付剩余购房款，给被害人造成了经济损失。那么，被告人曾某的行为究竟是无法支付剩余购房款的合同违约行为，还是合同诈骗行为？

区分合同诈骗行为与合同违约行为的关键在于判断行为人是否具有非法占有之目的。

尽管“非法占有目的”属于行为人的主观心理状态，但它必然通过一系列外化的客观行为表现出来，我们可以根据其客观行为表现以及行为效果推定行为人的主观心理态度。笔者认为，诈骗犯罪非法占有目的之认定，必须以行为人实施的客观行为活动为基础事实，综合考虑行为人事前、事中以及事后的各种主客观因素进行整体判断，只有从行为人的诈骗技术过程、各个行为环节着手，综合所有事实，经过周密的论证，排除其他可能，才能得出正确结论。

根据合同诈骗犯罪的特点，在司法认定非法占有目的的过程中，须综合考虑、审查分析以下几个要素：（1）行为人有无履约能力；（2）行为人有无采取诈骗的行为手段；（3）行为人有无履行合同的实际行动；（4）行为人对财物的主要处置形式。具体而言：

第一，审查行为人在签订合同时有无履约能力。当事人是否具备履约能力，直接关系到合同能否得到全面有效的履行，从而实现合同的目的。因此，当事人在签订合同时应当具备履约能力。在房产交易中，对买方而言，其履约能力就是具备相应的购房资格且能够按照约定的方式和时间足额支付购房款。具体到本案，被告人曾某作为房产交易中的买方，其应当具备依照合同约定支付全部购房款的能力。

本案中，判断被告人曾某是否具备履约能力，主要从以下几个方面来审查：一是审查财产状况，在案证据显示被告人曾某在签订合同时已背负高额债务，其名下没有资产，且缺乏稳定收入来源；二是审查购房首付款来源，曾某购房所支付的定金及首付款全部系借款而来；三是审查贷款还款能力，曾某个人征信记录不良无法按照约定从银行贷款支付剩余购房款，其签订合同时向被害人

出具的征信记录报告系其伪造的。据此认定被告人曾某不具备履约能力。

第二，审查行为人有无诈骗行为。主要审查行为人在签订和履行合同过程中有无实施虚构事实、隐瞒真相的行为，这是判断行为人内心非法占有目的的客观标准。

本案中，被告人曾某实施了多个诈骗行为，具体而言：一是签订合同时，向被害人出具伪造的个人征信报告，故意隐瞒其征信不良的情况；二是签订与履行合同过程中，虚构其有亲属在银行任职行长可帮其快速办理银行贷款；三是履行合同过程中，明知不可办理银行贷款仍以向银行办理抵押贷款为由骗取房产证；四是对被害人隐瞒其私自将房产抵押典当的事实。

第三，行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为。没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，这是通常讲的“钓鱼式合同”，是合同诈骗中常见的情形。

本案中，涉案房产价值300多万元，而被告人曾某仅支付了购房定金与首付款40万元，其以部分履行合同的方式骗取被害人的信任，诱骗被害人将房产证取件单交给其。其取得房产证后，并未按照其所称的向银行办理按揭贷款，也未积极创造条件履行支付剩余购房款义务。被告人曾某没有履行合同的实际行动。

第四，行为人对取得财物的处置情况，是否有挥霍挪用及携款潜逃等行为。被告人曾某取得房产证后，即通过典当抵押方式将涉案房产抵押给典当公司用于借款，所得280万元借款并未用于支付剩余购房款，反而在次日即将钱款全部转移，用于个人还款和消费等，恶意挥霍钱款，给被害人造成巨大经济损失。

综上，本案结合被告人的履约能力、诈骗行为、实际履行合同行为、财物处置方式等主客观因素，综合认定被告人具有非法占有目的，从而认定其行为构成合同诈骗罪。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 尤泽明 尹志泉

诈骗罪与合同诈骗罪的区分

—— 刘某某合同诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08刑终138号刑事判决书

2. 案由：合同诈骗罪

【基本案情】

2015年3月18日，某区政府与某1公司签订《投资合作框架协议书》，被告人刘某某作为某1公司的法定代表人在该协议书上签名，某1公司计划在某区投资建设《某现代家居·木业产业园》项目，但因该项目选址的土地是不能建设的土地，该项目至今未进行相关立项、审批、报建等手续。

2015年6月26日，某区政府与某2公司、某3公司签订《某家具木业现代产业园项目协议书》，刘某某作为某2公司的法定代表人在该协议书上签名，约定由某2公司、某3公司租赁位于某镇的约96亩工业用地作为《某家居木业现代产业园单板加工基地》项目用地，该项目总投资1.5亿元，并于同年10月22日在某区发展和改革局备案某2公司《关于年产150万立方米桉树单板加工基地建设》项目，该项目备案有效期为两年。至今，该项目也未进行相关立项、审批、报建等手续。

2019年12月25日，某有限公司、某1公司、某3公司共同成立某4公司，刘某某为某4公司的法定代表人。此后，刘某某在明知苏湾木业产业项目还没有进行相关土地变更、立项、审批、报建等手续的情况下，虚构项目相关手续

已完备，具备开工条件的事实，以某1公司、某4公司的名义与多家公司签订建设工程施工承包合同或监理合同，以缴纳诚意金、保证金就可以进场施工为由，先后骗取河北某公司、广东某公司、四川某公司、广西某公司、遂川县某公司、广西金路某公司等六家公司的工程项目诚意金、保证金共计人民币1179.1199万元，用于退还之前收取的其他公司的诚意金以及公司的日常运作和个人开支等。后经上述六家公司追讨，刘某某在案发前已退还广东某公司、四川某公司、遂川县某公司诚意金等共计人民币46万元，目前仍有1133.1199万元未退还。2022年6月1日，刘某某经通知后自行到案，并如实供述其在本案的全部罪行。

【案件焦点】

以虚构的工程项目为诱饵，从而与对方签订承建合同骗取钱财的行为应认定诈骗罪还是合同诈骗罪，两罪究竟如何区分。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为：被告人刘某某在实质上并没有开展与合同中约定的建设项目有关的经营活动，也没有履行合同能力或者没有履行合同意愿，只是通过签订合同方式取得六家公司的信任，以此骗取六家公司的诚意金、保证金。刘某某以非法占有为目的，虚构承建工程项目，及虚构项目已经具备开工条件，将项目建设工程发包承建为由签订合同，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，而符合诈骗罪的构成要件，应当认定为诈骗罪。刘某某自行到案并如实供述，是自首，且当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚及从宽处理。据此，以诈骗罪判处被告人刘某某有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元；责令被告人刘某某退赔被害人1133.1199万元。

一审宣判后，刘某某提出上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：上诉人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒其不具备履行合同的事实，骗取对

方当事人数额特别巨大财物，其行为构成合同诈骗罪。原判定性不当，依法予以纠正。一审认定事实清楚，证据确实充分，原判虽定性错误，但所作出的量刑适当。据此，判决如下：

一、维持贵港市港南区人民法院(2023)桂0803刑初2号刑事判决第二项中责令退赔被害人经济损失部分；

二、撤销贵港市港南区人民法院(2023)桂0803刑初2号刑事判决第一项对原审被告人刘某某的定罪、量刑部分；

三、上诉人(原审被告人)刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。

【法官后语】

本案被告人刘某某虚构工程项目，以签订承包合同或监理合同为名，骗取他人财物的行为构成犯罪，这一点是没有疑义的。但对其行为应定为诈骗罪还是合同诈骗罪，法院在对案件的定性上产生了分歧意见：一种意见认为，刘某某没有开展与合同有关的经营活动，也没有履行合同能力或意愿，只是通过签订合同方式骗取他人财产，其行为构成诈骗罪；另一种意见认为，刘某某利用合同这一合法形式，虚构工程项目，在签订、履行合同过程中骗取他人财产，应以合同诈骗罪论处。笔者认为，刘某某的行为应该认定为合同诈骗罪。具体分析如下：

一、诈骗罪与合同诈骗罪侵害客体的区分

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条与第二百二十四条规定之对比可见，合同诈骗罪相对于诈骗罪而言，是诈骗罪的一种特殊形态，二者在理论上属于法条竞合，因此在犯罪构成上有许多相似，但诈骗罪和合同诈骗罪仍也是有所区别的，应结合两者侵害的客体具体理解和把握。诈骗罪侵害的客体是单一客体，即国家、集体、个人合法的财产所有权。而合同诈骗罪规定于《中华人民共和国刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节“扰乱市场秩序罪”中，该罪不仅侵犯他人财产所有权，而且侵犯国家合同管理制度，破坏了社会主义市场经济秩序，故合同诈骗罪侵害的主要客体是市场交易秩序。

二、对合同诈骗罪中的“合同”界定

合同诈骗罪是一种利用合同进行诈骗的犯罪，诈骗行为发生在合同的签订、履行过程中，诈骗行为伴随着合同的签订、履行是此罪区别于诈骗罪的一个主要客观特征。合同诈骗罪以签订、履行合同或不履行合同为手段骗取财物，而诈骗罪则是采取任何手段骗取财物，但并非任何利用合同进行诈骗的行为都构成合同诈骗罪。合同诈骗罪中的“合同”，必须存在于合同诈骗罪所保护的客体范围内，能够体现一定的市场秩序，与市场秩序无关以及主要不受市场调整的各种“合同”“协议”，通常情况下不应视为合同诈骗罪中的“合同”，否则便与刑法的立法宗旨不符。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国刑法》的规定，合同诈骗罪中的“合同”是指在市场经济领域内，人们借以发挥关系的，签订与履行活动均受市场秩序制约的合同。

三、对“非法占有目的”的理解

对于合同诈骗罪的行为人而言，签订合同的着眼点不在合同本身的履行，而在对合同标的物或保证金的非法占有。判断行为人的行为是否构成合同诈骗罪，认定有无非法占有目的也是关键。如何在司法实际中判断行为人的主观目的，应当根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条所规定的具体行为认定，即：(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

四、“签订、履行合同”的判断

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪发生在“签订、履行合同过程中”，而诈骗罪的成立则没有这一要求。但是在诈骗罪中，行为人为了使对方陷入认识错误，也可能通过合同的形式来实施诈骗。因此，诈骗罪中也可能存在合同。对这种情形的认定，主要应当考察该合同是否属于经济往来活动中的合同，行为人骗取对方财物主要是通过合同实施，还是

仅仅将签订合同作为实施犯罪的一种具体手段。如果行为人与对方签订了合同，但行为人获得财物并不是利用合同实施欺骗的结果，而是通过虚构其他事实或者隐瞒其他真相而获得的，在这种情况下，即使在犯罪过程中存在合同，也应当认定为诈骗罪。此外，对于合同诈骗罪的行为人而言，签订、履行合同的目的在于合同的成立生效和本身的履行，而是对合同标的物或保证金等与签订、履行合同有关的财物的非法占有，而被害人也正是由于受骗陷入错误认识而“自愿”为了保证合同订立生效或按照合同的约定向诈骗人交付与合同内容相关的财物。如果行为人在与他人签订或履行合同的过程中，以其他与合同无关的事由为借口，骗取他人钱财的，则不是合同诈骗。

根据对合同诈骗罪犯罪构成要件综合分析，在本案中，一方面，刘某某作为某1公司、某4公司法定代表人，以虚构工程项目为噱头，通过网上招投标后，诱骗其他公司与之签订建设工程施工承包合同或监理合同，其他公司因签订的合同而事先支付诚意金或保证金。至此，双方建立合作关系。而双方签订的施工承包合同或监理合同，属于合同诈骗罪中的“合同”界定范围内。另一方面，刘某某及某1公司、某4公司均没有就《某现代家居·木业产业园》《关于年产150万立方米桉树单板加工基地建设》项目向相关职能部门申请立项、规划、审批、报建、施工许可等手续，该两个项目根本不具备开工建设的条件。在完全没有履行合同的能力情况下，刘某某仍然以某1公司、某4公司的名义分别与其他公司签订合同，而刘某某非法获取的被害公司钱财是来源于合同的诚意金或保证金，其骗取钱财的行为是伴随合同的签订、履行，其非法侵占的财物也是合同的标的物或其他与合同相关的财物。可见，本案签订、履行合同的过程中，自始至终存在虚构事实、隐瞒真相和实际履约不能。另外，本案证据显示，刘某某以法定代表人的身份与被害公司签订合同骗取财产后，刘某某并没有将所得意向金用于工程项目的筹备、推进、经营，而是用于部分退还之前收取的其他公司的意向金以及公司的日常运作和个人开支。为此，刘某某当时在既不具备合同履行能力的情况下，仍然未采取创造条件等积极履行行为反而消极推脱或者逃避履行义务，并将通过合同骗取的财产挪作他用，证

实刘某某签订合同是为了获取对方当事人的财物，具有非法占有之目的。被害公司因与刘某某签订合同而遭受财产损失1133.1199万元，同时也侵犯了财产所有权和市场交易秩序，符合合同诈骗罪关于犯罪客体的要求。由此，综合全案事实，本案中刘某某以非法占有为目的，虚构工程项目，利用与他人签订施工合同或监理合同的手段，骗取他人财产，因其是在签订、履行合同过程中骗取对方财物的，其行为完全符合合同诈骗罪的特征，应当以合同诈骗罪处罚。

编写人：广西壮族自治区贵港市中级人民法院 郑雪霞

12

知假购买是否构成生产、销售伪劣产品罪

——石油公司等生产、销售伪劣产品，虚开增值税专用发票案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02刑终302号刑事裁定书

2. 案由：生产、销售伪劣产品罪，虚开增值税专用发票罪

【基本案情】

1. 生产、销售伪劣产品部分

被告人黄某甲系被告单位石油公司、工贸公司、运输公司的实际控制人。2020年11月至2021年5月，石油公司伙同工贸公司、运输公司，为谋取非法利益，以石油公司为经营主体，批量向多家油库公司分别购买轻质循环油及航空煤油，由运输公司组织车辆将所采购的轻质循环油及航空煤油运至工贸公司厂区内存放。而后，在该厂区内将上述两种油品调和、着色，再以石油公司的名义并由运输公司组织车辆将在厂区已调和、着色的货值70117975.23元的油

品销售并运送给下游客户。2021年5月10日，公安机关在工贸公司厂区查获共计194.16吨、货值共计945559.2元的油品，并在下游客户陈某甲等经营的黑加油点查获部分已销售的油品。经检验，在上述地点查获的油品均为不合格车用柴油。黄某甲负责整个生产、销售非标柴油的决策、实施；黄某乙系石油公司业务员，负责销售非标柴油；王某某系工贸公司员工，负责调油；吴某某系石油公司的挂名法定代表人、工贸公司车队队长，负责车队管理、调度油品进货。

2. 虚开增值税专用发票部分

工程公司(已另案判决)于2020年10月、2021年2月先后二次通过施某某联系石油公司，在无实际货物交易的情况下，由石油公司虚开51份税额655752.42元及82份税额1035398.18元的增值税专用发票。后工程公司用上述发票抵扣税款1691150.6元。黄某甲作为石油公司的实际控制人，授意黄某丙等人具体实施虚开增值税专用发票行为；施某某系介绍人，负责联络开票事宜；黄某丙系石油公司财务主管，负责联系施某某，并根据黄某甲指示，授意黄某丁、钟某某制作合同、回流资金等；黄某丁系石油公司财务，负责确认收款和回流资金；钟某某系石油公司财务，负责制作购销合同和通知其他人员开票。石油公司赚取发票金额(含税)的3%。

【案件焦点】

部分购买者“知假”购买的情况下，被告单位、被告人是否构成冒充、欺骗，继而成立生产、销售伪劣产品罪。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区人民法院经审理认为：石油公司、工贸公司、运输公司明知系不合格产品仍冒充合格产品予以生产、销售，销售金额共计人民币70117975.23元、未销售货值共计人民币945559.2元，其行为均已构成生产、销售伪劣产品罪。黄某甲、黄某乙、王某某、吴某某作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为亦均构成生产、销售伪劣产品罪。其中，黄某甲、

王某某、吴某某生产、销售金额均为人民币70117975.23元，未销售货值均为人民币945559.2元；黄某乙销售金额为人民币30981558.73元。被告单位石油公司在没有实际油品交易的情况下，明知他人用于抵扣税款，仍为他人虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，属数额较大。黄某甲、黄某丙、黄某丁、钟某某作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为亦均构成虚开增值税专用发票罪。施某某作为虚开增值税发票行为的联络介绍人，其行为亦构成虚开增值税专用发票罪。

福建省厦门市海沧区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第一百五十五条、第二百零五条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告单位石油公司犯生产、销售伪劣产品罪以及虚开增值税专用发票罪，数罪并罚，决定执行罚金人民币1015万元。被告单位工贸公司、运输公司犯生产、销售伪劣产品罪，分别判处有期徒刑人民币1000万元。被告人黄某甲犯生产、销售伪劣产品罪、虚开增值税专用发票罪，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币300万元。被告人黄某乙、王某某、吴某某犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年至七年，并处罚金。被告人施某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。被告人黄某丙、黄某丁、钟某某分别判处有期徒刑一年八个月至十个月不等，并适用缓刑。

一审宣判后，被告单位石油公司、工贸公司、运输公司，被告人黄某甲、黄某乙、王某某、吴某某提出上诉。

福建省厦门市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的主要问题，部分购买者“知假”购买的情况下，被告单位、被告人是否构成冒充、欺骗，继而成立生产、销售伪劣产品罪。对该问题的分析，应

从如下几方面分析。

一、知假对象识别：是否为最终消费者

生产、销售伪劣产品罪侵犯的客体是消费者的合法权益及产品质量管理制度。故是否存在冒充、欺骗行为的对象应是消费者。《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条实质上明确了消费者的范围，即消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务。除自然人外，法人或者非法人组织都可以成为消费者。与消费者相对的经营者，是指为消费者提供其生产、销售的商品或者提供服务的群体，即生产者和销售者。从法律的角度而言，消费者的最终目的是满足生活需要。因此，基于生产、销售伪劣产品罪保护的法益的特殊性，知假的对象只能是消费者。

二、知假程度辨析：是否具有明确认知

“知假买假”是一个新的法律概念，是指消费者在明知即将购买和使用的商品是假货的情况，仍然购买、使用商品和接受服务的行为。在民事法律领域，“知假买假”一般只在“生活消费”范围内支持惩罚性赔偿，而超出部分会被认定为牟利目的，不受支持。具体到“以不合格产品冒充合格产品”情形，应明知即将购买的产品是不合格产品，《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款对产品质量进行了明确：（1）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；（2）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；（3）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。从规范角度说，只要不符合以上任一标准，即属于不合格产品，但从常理角度而言，普通消费者通常不具备相应的专业知识能准确识别或判断，产品是否应当符合特定标准，或无从获知各类产品的标准从而进行比对。因此，判断是否“明知”是不合格产品的程度，应从正常理性人的角度出发，产品是用于日常生活消费，产品至少应该具备两大特征：一是产品有用，具有相应使用性能；二是产品安全，不能产生于己有害的危险或影响。如果消费者明确知道产品无用或是不安全，即可以认定

其系“明知”产品不合格。

三、本案具体适用：是否构成冒充

本案油品的直接销售对象存在二类情况：第一类系油商、黑加油点等，其购买油品后，以柴油名义卖给用于车辆使用人。第二类的直接销售对象是涉案油品的直接消费者。

（一）黑加油点等“知假”购买行为能否认定为冒充

黑加油点等从实质上来说并非消费者，是中间流转环节的销售者，不是最终消费者。消费者并没有直接与本案被告单位、被告人进行直接接触，但被告单位、被告人将调和油品添加色，使油品接近柴油颜色的主观目的就是当柴油进行销售，因为添加色粉并不能改变油品的使用性能，纯粹就是为了包装成柴油的外观以便销售，被告人关于“我这个油品人家买去都是当国六在卖的”的微信聊天记录也证明被告人主观上明知这些油品被买过去是去当国六柴油在卖给车辆使用，被告人同时向黑加油点客户积极推销油品并达到增加其生产的伪劣产品销量的目的。因此，通过黑加油点等中间商进行销售，只是被告人为拓展销量的一种手段和方法，是为了找更多的消费群体，黑加油点找地越多，卖出去的油品就越多，受欺骗的消费者就越多，社会危害性就越大。被告单位、被告人的行为，实质上仍是欺骗最终消费者。

（二）部分消费者“知假”购买行为能否认定为冒充

在案证据显示，自用的这部分消费者在购买时，更关注油品的使用性能，因油是用在自己的车辆等设备，虽然该部分购买者出于节约成本考虑，但从常理而言，该部分消费者不至于会因为节约成本而置车辆受损的风险于不顾。部分消费者在购买油品时，被告人即使有告知其是“库油”“轻循环油”，但在消费者咨询油品能否给车辆使用时，被告人告知其性能跟柴油一样，可以给车辆使用，很多都是被买回去当国六再卖给车辆使用。显然这部分消费者也是在受欺骗情况下而购买。故即使被告单位、被告人在销售时明确告知部分客户是“库油”“轻循环油”的情形，但也不能掩盖其以不合格产品冒充合格产品，欺骗消费者的实质。

成品油是关系国计民生的基础性和战略性资源，成品油经营事关经济增长、安全环保等。在案证据足以认定被告单位及被告人明知勾兑的油品不合格，却仍然冒充柴油生产、销售的犯罪事实，部分中间销售商虽明知涉案油品不合格，但因其不是最终消费者，无法阻却冒充行为的欺骗性，部分直接购买的消费者虽知晓是“库油”“轻循环油”，但仍相信被告单位、被告人所售涉案油品是具有安全性和相当适用性能的，因此被告人的行为具有欺骗性，属《中华人民共和国刑法》第一百四十条所规定以不合格产品冒充合格产品的情形，依法构成生产、销售伪劣产品罪。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 卢建斌 陈芳序

如何认定发卡银行以信用卡透支形式变相发放贷款

——金某信用卡诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省长春市中级人民法院(2023)吉01刑终170号刑事判决书

2. 案由：信用卡诈骗罪

【基本案情】

2017年4月27日，上诉人金某向某信用卡中心申领某银行信用卡，核发额度为人民币100000元。《某银行信用卡领用合约》（以下简称《领用合约》）规定，某银行信用卡不支持现金提取及现金充值；境内、境外常规刷卡消费；通过互联网、电话、邮件等途径进行信用卡消费。《领用合约》同时规定持卡人申请某产品业务后，某产品转入持卡人同名的借记卡人民币账户，持卡人分

期按月足额偿还本金及手续费。2017年5月至2020年2月，金某通过电话多次向某银行申请某产品，某银行将金某所申请的某产品通过尾号3076某银行信用卡账户转入金某本人同名借记卡账户，金某将某产品支取后用于生活支出。2020年2月以后，金某未按《领用合约》规定按月足额偿还本金及手续费，2020年3月26日，某信用卡中心向金某短信提示总欠款人民币17988.51元；同年4月2日，向金某短信提示欠款人民币36527.26元；同年5月26日，向金某短信提示总欠款51629.06元；同年6月2日，向金某短信提示欠款68017.57元；同年6月3日、6月4日、6月6日、6月12日，向金某短信提示欠款51578.11元；同年7月9日，向金某短信提示欠款112664元。2022年10月27日，某银行向公安机关报案时金某总欠款134139.95元，其中本金99551.9元，利息0元，费用34588.05元。2020年11月4日，金某家属归还某银行100000元。

【案件焦点】

如何认定发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款。

【法院裁判要旨】

吉林省长春市南关区人民法院经审理认为：被告人金某以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。据此判决，被告人金某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元。

宣判后，金某提出上诉。

吉林省长春市中级人民法院认为原审判决认定事实不清、证据不足，裁定撤销原审判决，发回原审法院重新审理。本案发回后，吉林省长春市南关区人民法院重新审理了本案，重审后认定事实及定罪量刑均与第一次一审审理结果一致。

金某再次提出上诉。

吉林省长春市中级人民法院经审理认为：金某无法使用某银行信用卡直接现金提取与消费，其每次使用资金时须向某银行电话申请，该银行在金某申请

后将资金转入金某名下其他借记卡内，金某再将资金取出使用，金某申请某产品后即分期按月足额偿还，次月开始偿还本金及服务费。综合在案证据，某银行信用卡不具有现金提取、消费的服务功能，金某系向某银行借入资金，分期偿还，无免息还款期待遇，故金某所使用的某银行信用卡不具备透支型信用卡“透支消费”的本质特征，该卡系金某以信用为担保向某银行贷款的载体。综上，上诉人金某与发卡银行之间系金融借款纠纷，不适用“恶意透支”的规定。现有证据不能认定上诉人金某构成犯罪，依法予以纠正。原审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误。据此，判决如下：

- 一、撤销长春市南关区人民法院(2021)吉0102刑初518号刑事判决；
- 二、上诉人金某无罪。

【法官后语】

本案争议焦点在于如何认定发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款。

一、关于发卡银行变相发放贷款的认定

从金某信用卡诈骗无罪案件所涉及信用卡功能来看，案涉信用卡不具有常规认知的信用卡基本用途和使用方式，该卡无法刷卡消费和取现透支，持卡人将授信额度申请为现金，发卡银行将资金转账至持卡人同名借记卡，持卡人根据约定分期还款。经研究，上述信用卡所涉及业务形式系信用卡业务中的预借现金业务、分期还款业务的组合，归属于信用卡现金分期业务。经研究发现，2017年之前，信用卡具有社会普遍认知的刷卡消费和取现透支功能，持卡人仅能使用信用卡进行刷卡消费及现金提取，发卡银行对持卡人的授信额度不能直接申请为现金。随着信用卡业务的创新发展，2017年1月1日中国人民银行实施《关于信用卡业务有关事项的通知》（以下简称《信用卡业务通知》），该通知第四条规定：信用卡预借现金业务包括现金提取、现金转账和现金充值。现金转账，是指持卡人将信用卡预借现金额度内资金划转到本人银行结算账户。部分发卡银行对信用卡产品进行创新设计，发行以预借现金业务、分期还款业务组合的信用卡。因此类信用卡申领的便捷性，满足了持卡人对小额信贷资金的需求，此类产品在2017年之后逐渐发展，并且成为部分发卡银行的主力产

品。金某案中的信用卡正是上述信用卡业务的体现。

根据金某信用卡诈骗无罪一案反映的情况，通常理解金某向发卡银行申请的资金应属于贷款，1996年8月1日，中国人民银行施行《贷款通则》，《贷款通则》规定，本通则中的贷款系指贷款人对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。但人民银行于2018年对2017年12月31日之前发布的规章进行了全面清理，此次虽然未明文废止《贷款通则》，但《贷款通则》已不在现行有效的规章目录内。2024年1月30日国家金融监督管理总局公布《个人贷款管理办法》，仍规定信用卡透支不适用本办法。根据上述银行业法律、规章，可以推导出如下结论，认定信用卡现金分期业务是否属于贷款业务，并无现行有效的法律依据。

经研究认为，认定信用卡现金分期业务是否为现金分期贷款业务法律依据虽然不足，但对此种行为应以社会普遍认知的标准进行认定，持卡人将授信额度申请为现金，按照约定偿还发卡银行本金及利息的行为，应属于贷款行为。最高法院在相关民事诉讼中对于贷款行为所产生的金融借款纠纷也进行同性质认定，并且在与发卡银行主管部门、部分发卡银行座谈交流中对于现金分期还款业务就是贷款业务业已形成同一认识。故此，上述案件中金某与发卡银行之间系金融借款纠纷，发卡银行以信用卡透支形式变相发放贷款。

二、关于发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款中“违规”的认定

对于信用卡预借现金业务，2011年1月13日施行的《商业银行信用卡业务监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第五十五条规定，发卡银行不得为信用卡转账（转出）和支取现金提供超授信额度用卡服务。信用卡透支转账（转出）和支取现金的金额两者合计不得超过信用卡的现金提取授信额度。根据《管理办法》的规定，结合参考相关行业专业文章，金某案中发卡银行存在以下违规之处：一是发卡银行向持卡人预借现金数额违反总授信额度中扣减该笔预借现金业务额度的规定，根据上述规定，预借现金业务额度不得超过总授信额度的50%，金某案中发卡银行对其总授信额度10万元，金某经申请获得贷款约10万元，故此发卡银行存在违规行为；二是商业银行的信用卡现金提取授

信额度应等于信用卡透支转账和支取现金额度的总和，根据条文的文义解释现金提取的数额制约着信用卡透支转账的数额，案涉信用卡不具备信用卡现金提取功能的情况下，发卡银行不应将卡内资金透支转账至他人同名储蓄卡。

综上，根据案涉信用卡的功能及使用方法，无法认定上诉人金某的行为符合信用卡诈骗罪中“恶意透支”的认定，发卡银行与上诉人金某之间系金融借款纠纷，发卡银行违规以信用卡透支的形式变相发放贷款，故此，上诉人金某无罪。

编写人：吉林省长春市中级人民法院 王青松

公司业务员虚构交易事实实施诈骗的罪名认定

—— 李某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省徐州经济技术开发区人民法院(2023)苏0391刑初336号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2022年7月至2022年9月，被告人李某作为某工程机械公司的业务员，虚构向徐州某公司供应机械设备的事实，以其操控的某贸易公司、某商贸公司的名义与徐州某公司签订机械设备购买合同，骗取徐州某公司货款共计人民币2176.53万元，后被告人李某将上述全部违法所得用于赌博等。

案发后，被告人李某于2022年11月潜逃至境外，后于2022年12月20日返回国内投案。之后，李某将其自有的两套门面房作价50万元抵偿给被害单位徐州某公司指定的股东荣某名下。

【案件焦点】

1. 被告人虚构交易事实的行为如何定性；2. 被告人主观恶性的大小。

【法院裁判要旨】

江苏省徐州经济技术开发区人民法院经审理认为：首先，从犯罪主体看，李某不是合同的相对方，不符合合同诈骗的主体要件；其次，从客观方面看，李某虚构了相关交易事实，本案中所谓的购销合同，仅仅是一种形式和手段，买卖关系没有相关事实，亦没有履行合同的筹备、管理及经营活动，整个交易都是李某为了诈骗其公司财物而虚构的；再次，使被害单位陷入错误认识的主要因素是公司基于对李某的信任，而并非基于对合同的信任；最后，本案侵害的客体仅仅是李某所在公司的财产，而不是合同诈骗罪侵犯的客体即正常的市场交易秩序，故不符合合同诈骗的构成要件。综上，李某不构成合同诈骗罪，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。关于被告人的主观恶性大小，李某通过先后九次虚构供货交易的事实诈骗被害单位钱款2170余万元，诈骗次数多且数额特别巨大，同时，李某将犯罪所得用于赌博等违法活动，故不能认定其主观恶性小。江苏省徐州经济技术开发区人民法院于2024年2月6日判决：

一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币20万元；

二、被告人李某违法所得人民币2176.53万元，扣除已抵偿的人民币50万元，剩余违法所得人民币2126.53万元予以继续追缴后，发还被害单位某工程机械公司。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于李某虚构交易事实、假借合同骗取财物的行为是否构成合同诈骗罪。

一、诈骗罪与合同诈骗罪是法条竞合关系

通过欺诈的手段隐瞒真相，骗取公民的财物；犯罪的主体具备承担刑事责

任的能力；侵犯的客体是公私财物的所有权；在主观方面存在故意犯罪行为，并且以非法占有财物为目的，满足以上四个条件可以构成诈骗罪。对利用合同实施诈骗的行为最初是以诈骗罪论处的，如1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（已失效）第二条第一款规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。此后，1997年《中华人民共和国刑法》增设了第二百二十四条，明确对利用合同实施诈骗，数额较大的，以合同诈骗罪论处。可见，行为符合合同诈骗罪构成要件的，一般也同时符合诈骗罪的构成要件，两罪名之间是特别法条与普通法条的关系，属包容关系的法条竞合。故合同诈骗犯罪可以简单地理解为行为人在符合诈骗罪构成要件的基础上，利用合同实施诈骗，数额较大的行为。如果行为人通过利用合同以外的一般手段实施诈骗，则不存在诈骗罪与合同诈骗罪法条竞合的前提，达到诈骗罪数额较大标准的可直接以诈骗罪论处。因此，正确理解“利用合同实施诈骗”是区分两罪的关键。

二、准确把握诈骗罪与合同诈骗罪的侵犯法益和构成要件

诈骗罪与合同诈骗罪属于一般法与特殊法的关系，其联系在于都具有相似的客观特征与主观故意。而诈骗罪与合同诈骗罪存在侵害法益的不同。合同诈骗罪除侵害被害人财产利益外，还会损害市场秩序，而诈骗罪只侵害公私财产所有权，不涉及对秩序法益的侵害。诈骗行为使得被害人无法按照自己真实的意愿处分财物，违背市民生活中应当遵守的诚实信用原则，扰乱了基于信赖的交易秩序。其也是一种秩序犯罪。不过这种秩序法益不是诈骗罪主要法益，在认定诈骗罪时，不能仅以该秩序法益入罪。因此，秩序与财产，这两者法益在犯罪中的不同重要性才是特殊诈骗罪与一般诈骗罪的区别。

不仅如此，还可以从诈骗行为所要达到的程度对诈骗罪与合同诈骗罪进行区分。《中华人民共和国刑法》中规定的特殊诈骗罪大多涉及金融、集资、商事交易活动。在这些活动中，交易风险的存在是每个交易主体应当了解的基本情况。交易主体在明知交易风险的情况下依然选择进行交易，说明其放弃对自己权益的绝对保护。因此，在认定涉及合同、金融、集资的特殊诈骗罪时，应

当采取比一般诈骗罪更严格的标准。

利用合同实施诈骗是指行为人通过签订、履行合同过程中的虚假行为，使得相对方陷入错误认识，从而交付财物，实现其非法占有的目的。区分诈骗罪和合同诈骗罪应主要考察行为人与被害人之间是否签订合同，行为人是否实施了与合同内容有关的经济活动以及签订、履行合同是不是被害人陷入错误认识并处分财产的主要原因等方面。如果行为人与被害人签订了能够规制市场交易行为、体现市场秩序的合同，实施了与履行合同相关的筹备、管理和经营等活动，并通过签订、履行合同使被害人陷入错误认识继而处分财产，则可以认定行为人利用合同实施诈骗。

三、李某构成诈骗罪，不构成合同诈骗罪

具体到本案中，李某以其操控的某贸易公司、某商贸公司的名义与徐州某公司签订机械设备购买合同，并没有相应交易活动事实，合同仅仅是李某实现诈骗犯罪行为的工具和手段，其本意上并未从事任何与之相关的经济活动，未在合同履行方面进行准备。从侵犯法益上分析，合同诈骗行为“不仅侵犯他人财产所有权，而且侵犯国家合同管理制度，破坏了社会主义市场经济秩序”，其与普通诈骗罪的区别，就在于其联结着特定的市场运行机制，行为人的诈骗行为蕴含着对市场运行机制的侵蚀，有可能引发市场主体的逆选择而使市场交易秩序功能失调，故此，李某仅仅侵犯了他人的经济所有权，并未侵犯社会主义市场经济秩序，不应构成合同诈骗罪，仅是构成一般的诈骗罪。

综上所述，对于“合同”的把握不能片面关注一纸文书，应当采取一种社会功能主义的立场，审查“合同”背后的市场运行机制。与市场运行机制有关的，可能构成该罪；无关的，则只能另作考虑。“合同”是合同诈骗罪不可或缺的客观构成要件，缺少“合同”这个基本构成要素的诈骗行为不构成合同诈骗罪。同时，构成合同诈骗罪要求行为人必须实施与合同约定内容相关的经济活动，即具有签订、履行合同相关的筹备、管理和经营等活动。即便合同条款中明确了双方在经济活动过程中的权利义务，但行为人如不存在任何的筹备、管理和经营活动，仅仅将合同作为一种形式和手段，虚构合同关系继而达到骗

取财物的目的，亦不构成合同诈骗罪。本案中行为人客观上没有实施任何与合同相关的经济活动，“合同”即意味着仅是一个犯罪的工具，未实质上扰乱市场经济交易秩序，而仅仅是侵犯了他人的财产权利，应当以诈骗罪定罪量刑。

编写人：江苏省徐州经济技术开发区人民法院 王永毅 林一川

刑事推定在电信网络诈骗 犯罪认定涉案资金数额中的准确适用

—— 杨某等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02刑终154号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2020年11月，杨某在A国某酒店成立某公司，专门从事“杀猪盘”式电信诈骗活动。公司下设“旺财组”“鸿运组”“聚财组”“财神组”。罗某负责四个组全部人员的管理。杨某1负责资金流转，同时担任旺财组组长。周某系旺财组组员。各组组长以单身、离异女性为主要诈骗目标，先通过社交软件聊天建立信任，后将被害人推荐给组长(或代理)进行“精聊”，进一步诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取被害人钱款。自2020年11月至2021年3月，杨某、杨某1、罗某共参与骗取数十名被害人人民币360多万元。周某参与骗取多名被害人人民币100多万元。

【案件焦点】

刑事推定在电信网络诈骗犯罪认定涉案资金数额中如何准确适用。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：杨某、罗某、杨某1、周某在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。首先，本案多名同案(另案处理)的供述及证人证言均能证明四人实施了电信诈骗的犯罪行为；其次，公安机关从某公司调取的相关被害人注册信息显示涉及诈骗活动的公司负责人为杨某；最后，银行交易流水显示，部分被害人被骗的钱款均打入了同一人名下多个账户的情况十分频繁，上述部分收款账户的所有人参与了杨某的犯罪活动。综合全案证据分析，足以证明四人实施了电信诈骗的犯罪行为。杨某、罗某、杨某1是组织管理者，在共同犯罪过程中起主要作用，均为主犯。周某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，为从犯，依法可减轻处罚。四人在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚。最终以诈骗罪判处杨某有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币13万元；判处罗某有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币12.5万元；判处杨某1有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币12万元；判处周某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4.6万元；四人退赔被害人相应经济损失。

一审宣判后，杨某、罗某、杨某1提出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：上诉人(原审被告)杨某、罗某、杨某1, 原审被告周某在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。杨某、罗某、杨某1、周某在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚。杨某、罗某、杨某1在共同犯罪过程中起主要作用，均为主犯。周某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，是从犯，依法可减轻处罚。罗某、周某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。杨某有犯罪前科，可酌予从重

处罚。关于上诉人的上诉理由，经查，在案有同案犯供述、证人证言、被害人陈述、某网络科技有限公司出具的客户账号信息、银行账户明细等证据能够相互印证，证明杨某在A国某酒店伙同罗某、杨某1、周某等人利用某公司从事“杀猪盘”式电信诈骗活动。原判认定事实清楚，证据确实、充分，认定犯罪数额正确。杨某、罗某、杨某1、周某的行为均符合诈骗罪的构成要件。杨某、罗某、杨某1在共同犯罪中次要或辅助作用，原判认定上述三人为主犯正确。杨某、罗某虽从缅甸主动回国，但到案后并未如实供述主要犯罪事实，依法不构成自首。原判综合考虑杨某、罗某、杨某1、周某的犯罪性质、量刑情节及在共同犯罪中的作用等，对各上述四人所做量刑适当。北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

电信网络诈骗犯罪案件中，犯罪数额直接反映犯罪行为的社会危害性，是判断犯罪嫌疑人、被告人罪与非罪、罪轻罪重的关键考量因素之一。在传统印证证明规则的要求下，公安司法机关对于此类犯罪案件犯罪数额的确定存在过度依赖犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述等言词类证据的特点。当下在电信网络诈骗犯罪的推波助澜下，尤其是借助网络的非接触性、隐蔽性、被害人不特定性、涉案区域广泛性等不同于传统诈骗犯罪的特点，使得此类犯罪中被害方证据难以全部收集到位。证据收集存在碎片化、海量化的趋势，且被害人分散各地、难以查询，涉案资金频繁移转、快速取现，导致诈骗资金数额确定难。

在本案被告人涉案金额的认定方面，在满足本案基础事实的前提下，结合资金往来明细、交易记录以及部分被害人的陈述、同案犯的供述等多元证据，采取刑事推定证明方式，可综合认定被告人诈骗资金数额等犯罪事实。

首先，被害人难以查清，符合刑事推定的适用前提条件。

刑事推定是指依照法律规定、经验法则，基于基础事实，推定待证事实成

立的一种证明方式。推定是由基础事实推定待证事实的一种证明方式，集刑法与刑事诉讼法于一体，包括事实推定和法律推定两种类型，电信网络诈骗犯罪案件中，涉及的是事实推定。刑事推定不是证据裁判原则的例外，其是以间接证据为基础，通过逻辑思维及经验法则，以定罪事实为对象，允许被告人提出反驳，通过实质审查，构建严谨的证据体系。本案被告人杨某在境外成立公司，专门从事“杀猪盘”式电信诈骗。其组织多名成员通过社交软件寻找单身、离异女性作为诈骗对象，先通过聊天建立起信任，然后将被害人推荐给组长或代理进行“精聊”，进一步诱导被害人通过生物科技、蚂蚁金服等诈骗软件投资，骗取被害人钱款。由于被告人在境外通过多种网络平台对不特定的被害人实施诈骗，导致被害人人数难以查清、数额难以厘定，通过传统的印证模式证明方法难以实现。符合综合认定及刑事推定的前提条件。

其次，基础事实具有多元证据加以证实。

刑事证明包括直接证明和间接证明，刑事推定依赖间接证据，综合比对证据间的联系及证明对象的同一性和指向性，依赖整体效应来证明犯罪事实。作为推定前提的基础事实，须有客观证据加以证实，在基础事实认定的基础上，结合公诉方提出的其他间接证据，依赖逻辑思维和经验法则去论证基础事实与待证事实之间的关联性。基础事实层面，公诉机关通过出示的同案代某某、张某某等的供述，被害人李某某、甘某某、贺某等多人的陈述、报案材料、手机联系记录，证实了诈骗行为以及被害人款项打入被告人公司账户的事实存在，此基础事实既有被告人供述予以证实，还有部分被害人陈述、通话记录、银行交易明细等予以佐证，并且经公安机关从某网络科技公司调取的相关被害人注册信息显示涉及诈骗活动的公司负责人为杨某，故多元证据均证实基础事实的存在。

再次，基础事实与推定事实之间存在常态性。

基础事实与推定事实之间要求具有内在联系，两者之间具有前者引发后者的高度盖然性，基础事实与推定事实之间构建合乎逻辑的常态联系，这种常态性是基于长期、反复的社会实践检验，符合人类认知规律，且经检验论证的经验做法。经庭审质证的证据证实诈骗行为及被害人被骗成立的基础上，鉴于一

定时期内多名被害人及陌生款项打入被告人杨某控制的银行账户，在被告人杨某与被害人以及他人之间不存在正当的交易往来、资金借贷等法律关系存在的情况下，且上述事实发生在被告人诈骗行为持续期间，不仅有银行交易流水、手机联系记录等证据予以证实，还有言词性证据、报案材料等证据予以补充，考虑到基础事实与待证事实（汇入被告人银行账户的资金是诈骗资金）存在常态性、高概率可能，可以推定账户内资金为被告人诈骗数额。

最后，允许被告人提供线索或证据予以反驳。

允许被告人提出反证，其可以提供证据证实涉案款项中的某笔或多笔不属于诈骗金额，对公诉机关及审计报告的指控数额提出异议，但被告人在庭审质证过程中，并未提出有效的线索或证据材料。

综上，本案结合意见、司法解释及法理精神，不依赖于被告人供述及辩解、证人证言等言词证据，而是结合全案证据材料，采用刑事推定证明方法，可合理确定被告人的诈骗资金数额。

编写人：北京市东城区人民法院 石巍

双方曾有亲密关系的前提下， “违背妇女意志”应如何认定

—— 李某强奸案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省厦门市中级人民法院（2023）闽02刑终344号刑事裁定书

2. 案由：强奸罪

【基本案情】

李某与何某曾为同居情侣关系。2023年1月8日，何某通过微信向李某提出分手并从同居处搬离，后李某多次在微信中要求见面，何某均拒绝。2023年2月1日20时，李某用新注册微信冒充陌生女性，以介绍客户为由将前女友何某诱骗至某小区附近偏僻处。二人见面后，李某用手铐铐住何某并用刀具挟持，将其带上自己驾驶的汽车后，开车至临时租住的房间内。之后，李某以杀死何某与威胁被害人何某与其在一起。2023年2月2日凌晨，李某强行与何某发生性关系。8时许，李某提出与何某再次发生性关系，并将过程拍摄视频要挟何某，不让其离开。为取得李某信任，何某佯装同意并配合拍摄，与李某再次发生性关系。12时许，何某取得李某信任后，提出要去公司上班，李某将何某送至公司，后何某从公司逃跑至公安机关报警。同日18时许，李某在暂住处被抓获，民警在其身上扣押到手机、头套、手铐钥匙等物品，在其暂住处提取到刀具、手铐等物品，在其驾驶汽车上提取到望远镜、钥匙等物品。李某到案后对二人发生关系的事实无异议，但拒不承认其曾采取暴力胁迫手段，抗辩何某系自愿与其发生性关系。经鉴定，何某的阴道拭子、外阴拭子、胸部拭子，黑刀刀柄上均提取到李某的DNA（脱氧核糖核酸）。

【案件焦点】

针对被告人与被害人曾为同居情侣的亲密关系情形，如何判断二人发生性关系是否违背妇女意志。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区人民法院经审理认为：判断是否违背妇女意志，要全面分析被告人与被害人双方的现阶段关系、行为表现及心理状态，并结合行为发生的整个过程等因素进行综合判断。

首先，被告人李某与被害人何某之间没有发生性关系的感情基础。李某文与何某虽然曾经是同居男女朋友关系，但基于何某已于2023年1月8日提出分手并离开同居地，之后在被以加害相威胁的情况下，仍多次拒绝李某文的见面

要求，并已经重新结交新的男友。案发当天的见面也是因为李某文使用女性头像的微信佯装介绍客户使然。因此，被害人已经和被告人决然分手，时间已近一个月，没有再发生性关系的基础。

其次，被害人何某遇见被告人李某直至报警，始终处于被暴力控制和暴力胁迫之中。何某被诱骗至指定的地点后，随即被李某文用手铐铐住，当被害人反对跟从、关系复合、告诉手机密码、拍摄性行为视频时，即遭受被告人以刀割物以及展示手机内的弩、硫酸视频、购买订单等方式进行威胁，扬言杀害被害人及被害人家人进行恐吓，逼迫被害人就范，听令被告人摆布。整个过程被害人均处于被控制状态，使得被害人不能反抗、不敢反抗。

再次，被害人在脱离被告人控制后当即寻找机会报警，求助意愿强烈。被害人以上班为由求得脱身机会，由被告人开车将其送往就职公司，其下车后立刻从公司其他通道跑至网络搜索到的距离最近的派出所，报称被强奸。可见，被害人对违背自己意愿的性行为反应剧烈，报警及时。

最后，在案证据如监控视频中被告人持刀的画面，缴获的手铐、刀具、硫酸、望远镜、被割破的行李箱等物品，微信聊天记录，购买记录，证人何某某证言，可以印证被害人何某的陈述符合客观实际。虽然手铐、脚铐是被告人从情趣商店所购买，但上述物品足以用来作为实施暴力的工具，且被告人所称的购买硫酸是用于打扫卫生的说辞显然也与生活经验不符。因此，被告人的辩解与在案的多项证据相左，存在不实。综上，被告人李某文提出被害人系自愿发生性关系及其辩护人提出的本案未采取胁迫手段发生性关系的辩护意见不能成立。

据此，判决如下：

一、被告人李某犯强奸罪，判处有期徒刑五年；

二、随案移送的头套2个、移动电话2部、手铐2个、手铐钥匙3把、望远镜1个、刀具2把依法予以没收，扣押于公安机关的硫酸一瓶依法由公安机关处理。

一审宣判后，李某提出上诉。

福建省厦门市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

是否违背妇女意志是强奸罪犯罪构成的关键要素，其关键在于判断妇女对性行为的发生是否同意。若强奸行为发生于熟人之间，尤其是在被告人与被害人曾为情侣、同居甚至夫妻等亲密关系的前提下，判断性行为发生是否违背妇女意愿在司法实务中较难把握。本案系通过全面分析双方现阶段关系、行为表现及心理状态，并结合行为发生的整个过程等因素进行综合判断认定。

双方现阶段关系主要审查亲密关系的结束时间及方式、亲密关系结束后至当前双方的状态、是否有修复亲密关系的可能等，重点在于判断是否仍具有发生性关系的感情基础。具体到本案，李某文与何某分手至案发时间约一个月，何某在分手时直接从同居处搬离，分手后多次拒绝见面等均可体现其分手态度决然，且何某已重新结交新男友，案发时何某答应与李某文佯装的女性客户见面而非与李某文见面，可见并无与李某文重新修复关系的意愿，二人并无再次发生性关系的感情基础。

行为表现及心理状态重点在于审查性行为发生过程中是否存在暴力、胁迫行为，使得被害人不能反抗、不敢反抗。在熟人型强奸案件中，由于双方相识，行为人往往无使用暴力手段的明显特征而采取使用言语威胁等方式胁迫被害人配合。在此情形下，被害人伤痕、监控视频等客观证据较少，被告人与被害人就性行为发生是否存在暴力胁迫往往各执一词。本案双方性关系发生时拍摄的视频中虽无明显对抗行为，但应结合被害人所处环境、双方力量对比等进行考虑。何某被诱骗至指定的地点后随即被李某文用手铐铐住，当被害人反对跟从、关系复合、告诉手机密码、拍摄性行为视频时，即遭受被告人以刀割物以及展示手机内的弩、硫酸视频、购买订单等方式进行威胁，扬言杀害被害人及其家人进行恐吓，逼迫被害人就范，听令被告人摆布。整个过程被害人均处于被控制状态，使得被害人不能反抗、不敢反抗并出于恐惧和自我保护心理假意配合被告人发生性关系。

此外，性行为发生后被害人的表现，如是否报案、报案时间及动机、是否

脱离控制后仍停留现场、是否仍与被告人主动保持联系等，亦能辅证之前发生的性关系是否违背妇女意志。本案被害人在脱离被告人控制后第一时间报警，时间及时，可见其对违背自己意愿的性行为反应剧烈，主动寻求警方介入帮助。此外，被害人脱离控制后，被告人仍通过手机多次言语威胁被害人欲公开双方性关系视频，被害人均未予以回应，亦可证明被害人在被控制时的服从配合表现系出于自我保护目的的假意周旋。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 苏容

赌博罪和开设赌场罪的区分

——阿某某赌博案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区伽师县人民法院(2022)新3129刑初113号刑事判决书

2. 案由：赌博罪

【基本案情】

被告人阿某某以营利为目的，2021年11月24日至2021年11月25日在某乡的吐某某家，组织艾某某、库某某等13人赌博，提供赌具骰子，单局赌资在50元至200元，赌博过程中被告人阿某某收取1250元“抽头”后给房东吐某某400元，参与上述赌博的13名行为人的总赌资67700元。

被告人阿某某对指控的事实、罪名及量刑建议未提出异议，并自愿认罪认罚。

【案件焦点】

在自己和朋友的住处多次召集熟人以打麻将形式赌博，以“抽头”形式非法获利，聚众赌博的规模较小，利用其人际关系和人际资源来召集每一次的具体赌博活动的行为，认定赌博罪还是开设赌场罪？赌博罪和开设赌场罪如何区分？

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区伽师县人民法院经审理认为：从赌博规模上看，阿某某聚众赌博的规模较小，利用其人际关系和人际资源来召集每一次的具体赌博活动，召集几个熟人一起赌博，赌博的工具单一，赌博方式是打麻将，没有专门服务的人员，没有达到规模较大、赌博的工具齐全、赌博方式多样、有专门服务人员等开设赌场的程度。从赌博的场所来看，阿某某聚众赌博的场所具有不固定性，即聚众赌博的行为发生场所不固定，是在不同的住处进行，而不是在固定的营业地点和场所进行。从赌博的时间来看，阿某某聚众赌博的时间具有临时性、短暂性的特点，一般是在下班后或周末，一次赌博结束后，下一次赌博都是经阿某某临时召集，不具备开设赌场的时间具有持续性和稳定性，在一定持续长的时间内连续、不间断地为赌博人员开放，只要在其开放时间内，赌博人员来到赌场均能进行赌博活动，而无须赌场经营者临时组织、通知等特点；从赌博的范围和隐秘性看，阿某某聚众赌博具有隐秘性，阿某某在小范围内召集他人赌博，在每一次聚众赌博行为中其人员相对固定，其赌博行为只有参赌者知晓，不存在赌博的时间、地点、性质等被一定社会范围的公众知晓的情况。从以上几点分析，被告人阿某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人阿某某归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，退缴违法所得，依法可以从轻处罚。

新疆维吾尔自治区伽师县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第七十二条、第七十三条、第三百零三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人阿某某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金

1万元;

二、被告人阿某某违法所得1250元,予以追缴,上缴国库。

案件宣判后,判决已生效。

【法官后语】

1. 从聚众赌博和开设赌场的行为人在赌博活动中发挥组织吸引作用来讲,聚众赌博中,行为人要实施专门的“聚众”行为,往往需要行为人每次分别地招引他人赌博,如通过电话通知等方式。而开设赌场中,只要行为人开设了场子,这个场子在一定范围为人所知悉,那么,场子就可以自动起到吸引他人前来赌博的客观效果,而不需要被告人在此之外进行特别的广告、组织和吸引。

2. 自己的住处多次召集熟人以打麻将形式赌博,以“抽头”形式非法获利,聚众赌博的规模较小,利用其人际关系和人际资源来召集每一次的具体赌博活动,赌博的工具单一,没有专门服务的人员,赌博的时间具有临时性、短暂性,每一次赌博都是经阿某某临时召集,不具有持续性和稳定性、开放性,具有隐秘性,每一次赌博人员相对固定,其赌博行为只有参赌者知晓,不存在赌博的时间、地点、性质等被一定社会范围的公众知晓的情况,应当以聚众赌博罪定罪处罚。

开设赌场罪从原来的赌博罪分离出来,成为一个独立的罪名后,由于司法解释并没有对开设赌场罪的犯罪构成要件作出明确的规定,因而在司法实践中,在区分聚众赌博与开设赌场上不易把握。在该两罪名的区别认定上,关键就在于对“赌场”的认定。首先,开设赌场罪中所谓的“赌场”,除网络虚拟空间外,必须是一个物理性的封闭场所。当然,按照日常生活用语规则,露天进行赌博也可以称为“赌场”。其次,在具有物理性的封闭场所的前提下,要考察这一场所作为赌博所用场所是否具有固定性以及持续时间的长短等因素。从场所的固定性来看,如果是典型的状况下,如农村中的赌博,今天在张三家赌几天,明天在李四家赌几天,那么,张三或李四提供居所为他人赌博所用,就不能认为是开设赌场。但是,开设赌场的行为人出于逃避抓捕的目的往往会变动赌场的地点,特别是当赌场不是设在营业性的棋牌室或其他营业性场所时应认

定为赌场。从该场所作为赌博场所的持续性来看，事实上又很难确立一个具体的时间标准，而且由于被查获时间早晚的因素，这个“持续时间长短”具有偶然性，因而还需进一步分析。所以，判断是否是“赌场”，重点应该是看场所的社会影响，看这个场所是否为一定范围的人所知悉，更确切地说，看这个场所是否能独立地发挥吸引他人前来赌博的客观效应。

由于聚众赌博的行为人在赌博活动中要发挥组织吸引作用，开设赌场的行为人在赌博活动中也要发挥组织吸引作用，因而区分两者需要考察两者发挥组织吸引作用的方式。聚众赌博中，行为人要实施专门的“聚众”行为，往往需要行为人每次分别地招引他人赌博，如通过打电话通知等方式。而开设赌场中，只要行为人开设了场子，这个场子在一定范围为人所知悉，那么，场子就可以自动起到吸引他人前来赌博的客观效果，而不需要被告人在此之外进行特别的广告、组织和吸引。

聚众赌博与开设赌场均是赌博罪中常见的客观表现行为，均有为赌博提供场所、赌具等物质便利条件的行为。但二者在实践中还是有如下区别。

1. 聚众赌博的规模一般较小；而开设赌场的规模一般较大，其营业场所大，赌博的工具齐全，赌博方式多样，有专门为赌场服务的人员。

2. 聚众赌博的场所通常具有不固定性，即聚众赌博的行为发生场所通常不固定，有的是在临时租赁、借用他人的房屋内或者自己家中进行，有的是临时在宾馆里开房进行，有的甚至在公共场所进行；而开设赌场的赌博场所一般具有固定的营业地点和场所。

3. 聚众赌博的时间一般具有临时性、短暂性的特点，一般情况下，组织参赌人员在一次赌博结束后，下一次赌博又须组织者再次组织；而开设赌场的时间具有持续性和稳定性特点，即赌场在一定持续长的时间内连续、不间断地为赌博人员开放，只要在其开放时间内，赌博人员来到赌场均能进行赌博活动，而无须赌场经营者临时组织、通知。

4. 聚众赌博一般具有隐秘性，即组织者通常是在小范围内组织他人参赌，在每一次聚众赌博行为中其成员相对固定，其赌博行为一般只有组织者、参赌

者和为赌博服务的人知晓；而开设赌场一般具有半公开性，即赌场开设的时间、地点、性质等被一定社会范围的公众知晓。

5. 聚众赌博的赌头往往会利用其人际关系和人际资源来召集、组织每一次的具体赌博活动；开设赌场的经营者一般情况下不亲自参与召集、组织人员参与赌博。

6. 聚众赌博的赌头本人有时会参与赌博；开设赌场的经营者本人一般不会参与赌博。

编写人：新疆维吾尔自治区伽师县人民法院 阿布拉江 · 土尔迪

合同诈骗与职务侵占的区分

—— 曹某诈骗、职务侵占、冒充军人招摇撞骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市崇川区人民法院(2022)苏0602刑初192号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪、职务侵占罪、冒充军人招摇撞骗罪

【基本案情】

被告人曹某系托管公司员工，负责人事工作。2021年8月，被告人曹某经人介绍认识某超市(个体工商户)的经营者薛某。曹某在托管公司与薛某商谈采购物资事宜。根据曹某的指示，薛某2021年8月23日至9月8日分五次将医用手电筒、额温枪、N95口罩、冰箱、月饼等物品以及16台联想电脑、20部荣耀手机通过送货上门或者快递的形式送至托管公司，上述物品共计价值217656元，其中16台联想电脑每台8799元、20部荣耀手机每部3099元，电

脑和手机合计价值202764元。部分物品由被告人曹某直接签收，部分物品由托管公司门卫收货后转交曹某。托管公司对上述除电脑、手机外的部分物品进行了使用。2021年9月16日，曹某以托管公司名义与薛某签订了《办公用品及日常耗材采购合同》，合同甲方(购房)托管公司，乙方(供方)某超市。该合同上落款托管公司印章并非盖印形成，系曹某用扫描件打印形成。托管公司并未指派曹某购买16台电脑、20部手机。被告人曹某在收到上述电脑、手机后1部手机自用，将其余16台电脑、19部手机销赃给孙某某、陈某某，并将赃款用于挥霍、还债。被告人曹某另有诈骗、冒充军人招摇撞骗的犯罪事实予以省略。

【案件焦点】

被告人曹某未获托管公司授权以托管公司名义向薛某购买电脑、手机后销赃获利该行为的性质。

【法院裁判要旨】

江苏省南通市崇川区人民法院经审理认为：被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人曹某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪；被告人曹某冒充军人招摇撞骗，其行为构成冒充军人招摇撞骗罪。被告人曹某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人曹某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；其冒充军人多次诈骗，酌情从重处罚；其部分退赃，酌情从轻处罚。被告人曹某一人犯数罪，应当数罪并罚。

江苏省南通市崇川区人民法院判决：被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币10万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元；犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币11万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

对于本案被告人曹某上述行为的定性，审理中有两种意见：第一种意见认为，曹某构成职务侵占罪。理由是：曹某作为托管公司员工，以公司名义向薛某购买电脑和手机，系职务代理行为。薛某对曹某在单位的职权范围并不知情，属于善意相对人。电脑、手机送至某托管公司后曹某利用职务便利将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。第二种意见认为，曹某构成合同诈骗罪。理由是：曹某与薛某签订的采购合同上公司印章并非真实印章。曹某冒用单位名义与薛某签订合同，公司亦不追认，其行为应当视为个人行为。曹某明知其公司并不需要电脑、手机，仍然骗取薛某电脑、手机，数额较大，符合合同诈骗罪构成要件。笔者同意第一种意见，具体分析如下。

一、区分合同诈骗罪与职务侵占罪关键点之一：行为人实际占有的是本单位财物还是合同相对人财物

界定被告人曹某行为性质的关键在于其非法占有的电脑、手机的所有权归属。如果电脑、手机属于托管公司所有，则曹某的行为可能构成职务侵占罪；如果电脑、手机属于薛某所有，则曹某的行为可能构成合同诈骗罪。

1. 曹某的行为构成职务代理，其行为对托管公司发生法律效力

《中华人民共和国民法典》第一百七十条第一款规定了职务代理：执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。《中华人民共和国民法典》第一百七十条第二款规定了越权职务代理的法律后果：法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。职务代理的构成必须满足：（1）代理人是法人或者非法人组织的工作人员，如果代理人不是该法人或者非法人组织的工作人员，其按照被代理人的授权从事代理行为，属于一般的委托代理，比如保险公司正式员工不属于保险代理人，其展业行为系职务行为，视为保险人的行为，而保险代理人所从事的保险代理活动就属于一般的委托代理范畴。（2）代理人实施的必须是其职权范围内的事项，若非职权范围内的事项，则要区分情形适用该条第二款的规定等。

这一职权范围内的事项，可以理解为该法人或者非法人组织对该工作人员（即代理人）的一揽子授权，无须在每次与第三人交易时都要提交有关书面授权书，其职务、职权本身就是委托授权的证明。这也是职务代理与一般的委托代理在交易便捷方面的很大不同。（3）必须以该法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，这也是代理的一般构成要件。若非以该法人或者非法人组织名义实施民事法律行为，则会构成无权处分或者侵权行为，应该分别适用不同的法律规则。该条明确了“职权限制不得对抗善意相对人”的规则，也就是说只要交易相对人对该职权限制不知情，即产生该条第一款规定的合法有效职务代理的法律后果。超越职权职务代理与表见代理不同，从构成要件上并没有如同表见代理要求相对人举证证明其有理由相信代理人有代理权这一要件。

本案中，被告人曹某的行为构成越权职务代理，不得对抗善意相对人薛某。首先，被告人曹某是托管公司员工，以托管公司的名义向薛某采购物资，包括电脑、手机在内的物资也均是送货到托管公司。其次，薛某是善意相对人。被告人曹某与薛某商谈物资采购是在托管公司内。在电脑、手机送货上门之前薛某已经将医用手电筒、额温枪、N95口罩以及租赁给托管公司的冰箱、除湿机等物品送至托管公司，托管公司对上述部分物品也进行了使用。虽然电脑、手机的价值大但也属于办公用品，并且采购电脑手机之前也租赁过冰箱、除湿机等大型物资。上述事实可见薛某对被告人曹某在公司的职权范围并不知情，即薛某不知道被告人曹某有无权限采购电脑、手机。被告人曹某越权职务代理采购电脑、手机的行为，因薛某是善意相对人，故不得对抗薛某，对托管公司发生法律效力。

2. 曹某非法占有的财产属于托管公司的财产

首先，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。本案中，在被告人曹某与薛某签订《办公用品及日常耗材采购合同》之前，薛某已经将货物全部送至托管公司。合同上印章的真伪并不影响合同成立。其次，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，

但是法律另有规定的除外。电脑、手机送至托管公司后，所有权人转移为托管公司。

二、区分合同诈骗罪与职务侵占罪关键点之二：行为人取得财物主要是利用了职务便利还是采取了欺骗手段

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。当名义职务与实际职务范围不一致时，应以实际职务范围为标准，判断行为人是否利用了职务之便。本案被告人曹某在托管公司负责人事工作，名义上并没有采购物资的职权。但结合证据看，托管公司对曹某采购的物资进行了使用，说明其公司采购制度存在一定的漏洞。正因如此曹某才能利用职务的便利擅自采购电脑、手机并将电脑、手机非法占有。本案中，被告人曹某非法占有电脑、手机的行为本质仍然是一种利用职务便利的行为，故符合职务侵占罪犯罪构成要件。

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案在（口头）签订及履行该合同过程中，曹某既没有实施《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定中所列举的五种客观行为，也没实施普通诈骗罪所强调的虚构事实，隐瞒真相行为。原因就在于，其有职权之便，而根本不需要行欺骗之举。同时，就合同相对人薛某而言，其之所以交付货物，并非由于受到被告人的欺骗，而是基于对被告人职务代理行为的肯定及对托管公司所具履行能力的信任。其交付货物行为出于真正的自愿，而非表面的自愿。因而，从薛某的角度看，其交付货物的心理特征也不符合一般诈骗罪中被害人的心理表现形式。

综上，本案被告人占有财物的成功，主要是假借职务之便，而非假借其“骗术”；被告人最后实际占有的是权属本单位所有的财物，而非合同相对人薛某所有的财物。根据被告人的身份，结合其利用职务之便，侵吞本单位财物的行为，应该认定其侵占217656元物品的行为构成职务侵占罪，而非合同诈骗罪。

编写人：江苏省南通市崇川区人民法院 陈程

明知是未满十四周岁幼女仍容留、介绍卖淫的行为如何定性

——谢某甲、唐某强奸，容留、介绍卖淫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区河池市中级人民法院(2023)桂12刑终152号刑事裁定书

2. 案由：强奸罪，容留、介绍卖淫罪

【基本案情】

2020年8月，被告人谢某甲在某奶茶店认识未成年人蒙某某(十二岁)，蒙某某系小学六年级学生。2020年9月，谢某甲在某奶茶店认识未成年人彭某某(十五岁)、张某(十四岁)，张某、彭某某系初中学生。谢某甲知晓蒙某某是某小学六年级学生，知晓张某、彭某某是某中学学生。自2020年9月开始，谢某甲单独容留、介绍蒙某某在其家中卖淫，2020年10月，谢某甲又同时与被告人唐某共同容留、介绍张某、彭某某卖淫。谢某甲还与蒙某某、谢某乙(十三岁)发生性关系。具体犯罪事实如下。

1. 2020年10月，被告人谢某甲与被告人唐某经商量决定共同介绍初中生彭某某、张某从事卖淫活动，并让彭某某、张某在唐某经营的杂货店门前站街、在杂货店附近的一房间与嫖客发生性关系一次。唐某还负责“放风”，谢某甲负责联系彭某某、张某到酒店场所提供上门服务，还提供收款二维码收取全部嫖客的嫖资。2020年10月至2021年4月，谢某甲、唐某多次容留、介绍彭某某、张某从事卖淫活动，谢某甲、唐某均分提成，各非法获利约4000元。

2. 2020年9月至2021年6月，被告人谢某甲为蒙某某介绍嫖客。因蒙某

某在校读书，谢某甲联系好嫖客，再接蒙某某到其家中从事卖淫活动，并收取嫖资。

3. 2021年5月或6月某天晚上，被告人谢某甲在某酒店房间里与幼女蒙某某发生性关系一次。

4. 2021年4月，被告人谢某甲经蒙某某介绍认识谢某乙（初一学生）。谢某甲知晓谢某乙是蒙某某的闺蜜。同年6月29日凌晨，谢某乙与蒙某某、谢某丙等人在谢某甲家玩耍，后谢某甲以不送谢某乙回家为由威胁、胁迫谢某乙与其发生性关系，发生性关系前谢某甲发现谢某乙尚未发育完全。同年7月1日凌晨，谢某乙、蒙某某等人在谢某甲家玩耍，谢某甲在其家中房间与谢某乙又发生性关系一次。

【案件焦点】

本案犯罪行为发生在2020年至2021年，在当时的法律背景下，谢某甲明知蒙某某是幼女仍将其介绍给嫖客并提供卖淫场所，在嫖客不到案或无法证实嫖客是否明知蒙某某是幼女的情况下，谢某甲成立强奸罪还是成立容留、介绍卖淫罪。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院经审理认为：被告人谢某甲、唐某共同容留、介绍未成年人卖淫，其中被告人谢某甲容留、介绍彭某某、张某、蒙某某三名未成年人卖淫，被告人唐某容留、介绍彭某某、张某二名未成年人卖淫，均构成容留、介绍卖淫罪。被告人谢某甲明知被害人蒙某某、谢某某是幼女，仍与被害人蒙某某发生性关系一次，与被害人谢某某发生性关系两次，属于奸淫幼女，构成强奸罪。在共同容留、介绍未成年人的犯罪中，谢某甲、唐某二人经合谋后分工合作，作用相当、地位相同，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。唐某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。谢某甲、唐某多次容留、介绍在校未成年人卖淫，更加应当从重处罚。唐某被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再故意

犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。谢某甲一人犯数罪，对其数罪并罚。为维护社会治安管理秩序及保护未成年人合法权益，根据被告人谢某甲、唐某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，判决如下：

一、被告人谢某甲犯强奸罪，判处有期徒刑六年；犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币12000元；总和刑期十年六个月，并处罚金人民币12000元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币12000元；

二、被告人唐某犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；

三、对被告人谢某甲的违法所得人民币4000元、被告人唐某的违法所得人民币4000元，予以追缴，上缴国库。

一审宣判后，谢某甲提出上诉。

广西壮族自治区河池市中级人民法院同意一审法院的裁判意见，裁定：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

从2003年1月24日施行的《最高人民法院关于行为人不明知是不满十四周岁的幼女双方自愿发生性关系是否构成强奸罪问题的批复》（已失效），到2013年10月23日颁布实施的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》（以下简称《性侵意见》，已失效），再到2023年5月24日颁布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理性侵害未成年人刑事案件的意见》，前后三部司法解释性文件的颁布、废除过程以及《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理性侵害未成年人刑事案件的意见》第十七条设置的立法本意、文字表述来看，对于已满十二周岁不满十四周岁的幼女实施奸淫等性侵行为，若无极其特殊的例外情况，一般都应当认定行为人“明知”被害人是幼女。除非有合理证据证实行为人根本不可能知道被害人是幼女，或者行为人已足够谨慎行事仍对幼女年龄产生误会，否则应当认定行为人明知被害人是幼女。在本案中，谢

某甲与蒙某某长期接触且自认知晓蒙某某是小学六年级的学生，而小学六年级 学生常见年龄为十二岁至十三岁，初中学生常见年龄为十二周岁至十五周岁。 谢某甲作为一个二十五周岁的成年人，具有正常认知判断能力，通过外表、读 书情况应当能够引起谢某甲对被害人实际年龄的警觉，但其没有采取任何措施进一步核实被害人的实际年龄，亦未提供其确实不知被害人不满十四周岁的有 效证据。据此，现有证据足以认定谢某甲明知被害人蒙某某是幼女。

在此情况下，对于蒙某某而言，谢某甲除构成强奸罪，其还为蒙某某介绍 嫖客、接蒙某某到其家中从事卖淫活动、收取嫖资。对此行为在司法实践中存 在争议，一种意见认为此案行为发生在《性侵意见》废止前，根据该意见第二 十四条的规定，介绍、帮助他人奸淫幼女、猥亵儿童的，以强奸罪、猥亵儿童罪的共犯论处。谢某甲应以强奸罪共犯论处。另一种意见认为谢某甲具有容留、 介绍蒙某某卖淫的事实，应构成容留、介绍卖淫罪。

笔者赞成后一种意见。首先，本案中仅有证据证实谢某甲明知蒙某某系不 满十四周岁的幼女，但与蒙某某发生性关系的嫖客并未到案，公诉机关亦未提 起公诉，在案证据也无法排除谢某甲利用嫖客的不知情或采取欺骗手段促使嫖 客与被害人发生性关系的可能，因此没有办法认定嫖客是否“主观明知”蒙某 某系幼女或是有奸淫幼女的故意，无法认定嫖客构成强奸罪。在这种情况下， 谢某甲与嫖客没有共同的犯意，也没有基于共同意思联络的犯罪行为。故无法 认定谢某甲构成强奸罪共犯。其次，

谢某甲的犯罪行为符合容留、介绍卖淫罪的构成要件。《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款规定的引诱、容留、介绍他人卖淫罪，是一个罪名的选择性规定，这三种行为只要实施了其中一种行为，即可构成犯罪。另外，本条规定中“引诱、容留、介绍他人卖淫”中的“他人”并无年龄限制，这说明介绍、容留他人卖淫包含介绍、容留幼女卖淫的情形，介绍、容留幼女卖淫也可以成立容留、介绍卖淫罪。至于《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第二款单独设置引诱幼女卖淫罪，笔者认为此罪是作为引诱卖淫罪的特殊类型，属于情节严重情形，所以法定刑是在五年以上有期徒刑，从立法本意来看这也是基于对幼女的特殊保护。具体到本案中，

案发时谢某甲已年满十八周岁，具有刑事责任能力，是合格的犯罪主体；谢某甲主观上具有容留、介绍他人与蒙某某发生性关系以此牟利的主观故意，并基于此多次实施为卖淫者蒙某某介绍嫖客、接送蒙某某、在蒙某某和嫖客之间牵线搭桥、沟通撮合、提供场所促使卖淫嫖娼活动得以实现的行为；该犯罪行为已然对社会善良风化的形成造成恶劣影响、妨害社会管理秩序。在此罪名认定中，蒙某某是否幼女不影响本罪的成立。因此，谢某甲的行为构成容留、介绍他人卖淫罪。

编写人：广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院 冉杰

未成年人特殊群体犯罪与恶势力组织犯罪的区分①

—— 高某等故意伤害、强奸、寻衅滋事案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省高级人民法院(2021)冀刑终331号刑事裁定书

2. 案由：故意伤害罪、强奸罪、寻衅滋事罪

【基本案情】

被告人李某某(十九周岁)、高某(十五周岁)相互勾结，发展被告人代某某(十五周岁)、郭某某(十四周岁)与潘某某(十三周岁，另案处理)、伦某某(十三周岁，另案处理)等人为“小弟”，形成以李某某、高某为首，代某某、郭某某与潘某某、伦某某等人为固定成员的恶势力团伙。该团伙聚集

①入库案例，参见人民法院案例库2023-04-1-179-014。

在隆化县某中学附近，发展在校学生为“小弟”，多次采用辱骂、强迫观看打人视频等手段威胁、恐吓学生，随意拦截殴打学生，索要财物。严重影响学生正常学习生活，严重扰乱学校正常管理秩序。该团伙实施犯罪故意伤害致人死亡一起、强奸三起、寻衅滋事一起，实施殴打在校学生并拍摄视频的违法行为二起。

河北省高级人民法院经审理查明的事实与一审一致，但未认定李某某、高某等人为恶势力。具体犯罪事实如下。

（一）故意伤害事实

2020年11月1日21时许，在某甲镇某甲村伦某某家老房子内，被告人李某某、高某认为被害人张某某挑拨二人关系，遂要“教训”张某某，二人指使被告人代某某、郭某某与潘某某、伦某某殴打张某某，潘某某用金属棒球棍击打张某某头部数下，被告人代某某、郭某某与伦某某对张某某拳打脚踢，致张某某当场死亡。经鉴定，张某某系被他人以钝器打击头部致颅脑损伤死亡。后被害人张某某亲属与被告人代某某、郭某某的法定代理人达成调解。